

Haftpflichtkommentar

Art. 41 OR

WILLI FISCHER, in:

Willi Fischer, Thierry Luterbacher

Haftpflichtkommentar - Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen

1. Auflage, 2016

Dike Verlag AG, ISBN 978-3-03751-685-0

[Seite 83] Art. 41 OR

A. Haftung im Allgemeinen

I. Voraussetzungen der Haftung

¹ Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.

² Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.

[version française]

Art. 41 CO

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

¹ Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

² Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer.

[versione italiana]

Art. 41 CO

A. Responsabilità in generale

I. Requisiti della responsabilità

¹ Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

² Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

INHALTSVERZEICHNIS

	Note
I. Anwendungsbereich von Art. 41 OR	1
A. Grundsatz der Universalität	1
B. Anspruchskonkurrenz	3
C. Anspruchskonkurrenz und Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse	7
D. Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspruch	13
II. Voraussetzungen der ausservertraglichen Verschuldenshaftung	14
A. Anspruchsvoraussetzungen im Überblick	14
B. Schaden im Rechtssinne	15
1. Allgemeines	15

2. Herrschender, klassischer Schadensbegriff	17
3. Wertende Korrekturen der Differenztheorie	26
3.1 Ausgangspunkt	26
3.2 Normativer Schaden	27
3.3 Kommerzialisierungs- und Frustrationsschaden	29
a) Allgemeines	29
b) Kommerzialisierungsschaden	30
c) Frustrationsschaden	36
4. Schadensarten	40
4.1 «Damnum emergens»/«lucrum cessans»	40
4.2 Unmittelbarer und mittelbarer Schaden	41
[Seite 84] 4.3 Personenschaden	46
4.4 Sachschaden	47
4.5 Sonstiger und reiner Vermögensschaden	53
4.6 Direkter und indirekter Schaden/Reflex- und Drittschaden	56
4.7 Schockschäden Dritter	57
C. Widerrechtlichkeit	58
1. Allgemeines	58
1.1 Bedeutung und Funktion der Widerrechtlichkeit	58
1.2 Widerrechtlichkeitstheorien	62
a) Objektive Widerrechtlichkeitstheorie	62
b) Subjektive Widerrechtlichkeitstheorie	72
c) Sog. «dritte Widerrechtlichkeitstheorie»	77
2. Objektive Widerrechtlichkeitstheorie als (einheitliche) Normwiderrechtlichkeit im Besonderen	80
2.1 Erfolgsunrecht als Verhaltensunrecht	80
2.2 Normwiderrechtlichkeit (Verhaltensunrecht) als umfassende Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR	90
3. Treu und Glauben als absolutes Recht bzw. Grundschutznorm	92
4. Widerrechtlichkeit durch Unterlassung (Verletzung einer Garantenstellung) im Besonderen	103
4.1 Grundsatz der befugten Untätigkeit	103
4.2 Ausnahme: konkrete Handlungspflichten	104
5. Vertrauenshaftung	108
6. Ausschluss der Widerrechtlichkeit durch Rechtfertigungsgründe	114
6.1 Allgemeines	114

6.2 Überblick über die Rechtfertigungsgründe	115
6.3 Einzelne Rechtfertigungsgründe	116
a) Ausübung öffentlicher Gewalt (Amtshandlungen)	116
b) Subjektive Privatrechte	118
c) Einwilligung des Geschädigten	119
d) Wahrung höherer Interessen	128
e) Private Rechtfertigungsgründe	129
D. Kausalzusammenhang	130
1. Allgemeines	130
2. Natürlicher Kausalzusammenhang	131
3. Adäquater Kausalzusammenhang	135
3.1 Begriff	135
3.2 Adäquanz bei Unterlassung	138
3.3 Fehlende Adäquanz	140
a) An sich inadäquater Kausalzusammenhang	140
b) Wegfall/Unterbrechung der Adäquanz	141
3.4 Besondere Kausalitätsformen	147
E. Verschulden	151
1. Verschulden als Haftungszurechnungsgrund	151
2. Begriff und Funktion	152
3. Verschuldenskomponenten	157
3.1 Überblick	157
3.2 Urteilsfähigkeit als subjektive Verschuldenskomponente	159
3.3 Vorsatz oder Fahrlässigkeit als objektive Verschuldenskomponente	163
a) Vorsatz (Absicht)	163
b) Fahrlässigkeit	165
aa) Allgemeines	165
bb) Arten der Fahrlässigkeit	168
[Seite 85] cc) Hilfsmittel zur Feststellung der Fahrlässigkeit	173
4. Verschulden bei der Haftung einer juristischen Person	175
5. Substitution des Verschuldens	176
III. Haftpflicht versus Schadenersatzpflicht	177
IV. Absichtliche Schädigung wider die guten Sitten (Abs. 2)	179

I. Anwendungsbereich von Art. 41 OR

A. Grundsatz der Universalität

Die Verschuldenshaftung gemäss **Art. 41 Abs. 1 OR** stellt die Grundnorm, die Regel **1**
im geltenden Haftpflichtrecht dar¹ und findet überall dort Anwendung, wo im
konkreten Fall keine sie verdrängende Spezialnorm vorgeht (Grundsatz der
Universalität).² «Eine spezielle Haftungsnorm geht Art. 41 als **lex specialis** i.d.R. vor,
wenn nach ihr dieselbe Person schadenersatzpflichtig wird, die ohne die
Sondernorm der Verschuldenshaftung unterliegen würde.»³ Dies gilt z.B. im
Verhältnis der Kausalhaftungen als *leges specialis* gegenüber der
Verschuldenshaftung.⁴

Trotz Vorliegens von Spezialbestimmungen können **Art. 41 ff. OR** trotzdem **2**
Anwendung finden, sofern die Spezialbestimmungen auf die Verschuldenshaftung
verweisen (wie z.B. die Globalverweisung von **Art. 99 Abs. 3 OR**, **Art. 31 Abs. 3 OR**,
Art. 62 Abs. 1 SVG).⁵ Im Übrigen werden die allgemeinen Normen auch
herangezogen, wo eine Spezialnorm eine Frage offenlässt.⁶

B. Anspruchskonkurrenz

Anspruchskonkurrenz besteht mit der **vertraglichen Haftung**. Durch die Verletzung **3**
einer vertraglichen Pflicht kann u.U. gleichzeitig auch eine unerlaubte Handlung
(**Art. 41 Abs. 1 OR** oder einfacher Kausalhaftungstatbestand) begangen werden; in
einem solchen Fall ist der Geschädigte i.S. der Anspruchskonkurrenz berechtigt,
sich «nebeneinander auf beide Haftungsgründe zu berufen».⁷

[Seite 86] Anspruchskonkurrenz herrscht nach heute h.M. aber nicht nur zwischen **4**
den Haftungstatbeständen des Vertragsrechts und jenen des Haftpflichtrechts des OR
und des ZGB (vgl. N 3), sondern auch zwischen

- **Verschuldenshaftung** nach **Art. 41 Abs. 1 OR** und den **gewöhnlichen Kausalhaftungen**⁸
sowie
- **vertraglicher Haftung** und den **spezialgesetzlichen Gefährdungshaftungen**⁹ und
- den **ausservertraglichen Haftungstatbeständen des OR/ZGB** und den
spezialgesetzlichen Gefährdungshaftungen.¹⁰ Diese Anspruchskonkurrenz ist
entgegen den ablehnenden Meinungen¹¹ zu befürworten, als mit SCHWENZER nicht
einzusehen ist, warum eine Berufung auf das Recht der unerlaubten Handlung von **Art.**
41 ff. OR versagt werden soll, wenn diese Tatbestände weiter reichen als die fragliche
Gefährdungshaftung.¹²

Gemäss **Art. 11 Abs. 2 PrHG** bleiben Schadenersatzansprüche aufgrund des OR oder **5**
anderer Haftpflichtnormen der eidgenössischen oder kantonalen Rechtsordnung
gewahrt. Ein Geschädigter kann sich deshalb auf diese Normen berufen; es herrscht
Anspruchskonkurrenz.¹³ Kontrovers ist, ob die spezialgesetzlichen
Gefährdungshaftungstatbestände, die im Verhältnis zum OR als ausschliesslich
anwendbar betrachtet werden (SVG, EleG, USG), wahlweise neben PrHG-Haftung
anwendbar sind. Mit REY sind die Normen als alternativ anwendbar zu betrachten,
bringt doch **Art. 11 Abs. 3 PrHG** nur einen Vorbehalt hinsichtlich der Haftung für
nukleare Zwischenfälle an.¹⁴ Gegenüber Spezialgesetzen, welche die Materie
erschöpfend regeln (z.B. Immaterialgüterrecht) und die gegenüber dem
allgemeinen Recht erhöhten Schutz bieten, existiert keine Anspruchskonkurrenz.¹⁵

Als Folge der Anspruchskonkurrenz muss der Richter selbständig die **6**
Tatbestandsvoraussetzungen prüfen, da er das Recht von Amtes wegen anzuwenden
hat (**Art. 57 ZPO**).¹⁶ Die Bedeutung der Anspruchskonkurrenz zeigt sich u.a. auch
hinsichtlich der Beweislast sowie vor allem auch bezüglich der Verjährung.¹⁷

[Seite 87] C. Anspruchskonkurrenz und Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse

Während im Rahmen der Anspruchskonkurrenz zwischen Delikts- und **7**
Vertragsansprüchen der deliktische Anspruch keinen Einfluss auf den vertraglichen

Anspruch hat (z.B. Nichtübertragung der relativen Verjährungsfrist auf Vertragsanspruch),¹⁸ ist dies umgekehrt durch das konkurrierende Vertragsrecht sehr wohl möglich.¹⁹

Will bspw. eine **gesetzlich vorgesehene Haftungsmilderung** (z.B. Art. 248 Abs. 1 oder **Art. 420 Abs. 2 OR**) nicht durch einen konkurrierenden Deliktsanspruch unterlaufen werden, so muss sie auch für den Deliktsanspruch gelten.²⁰ **8**

Nach h.L. und Rechtsprechung wirkt ein **vertraglich vereinbarter Haftungsausschluss** bzw. eine **vertragliche Haftungsbeschränkung** auch bei einem konkurrierenden Deliktsanspruch.²¹ Entscheidend ist in dieser Frage immer der Parteiwille, d.h., es ist eine Frage der Auslegung, aus der resultieren muss, dass nebst der vertraglichen auch die ausservertraglichen Ansprüche ausgeschlossen oder beschränkt sein sollen.²² Bestehen Zweifel bez. des Vertragswillens, ist keine Ausdehnung der vertraglichen Regelung auf das Deliktsrecht anzunehmen.²³ **9**

Haftungsausschlüsse sind einzig in den Grenzen des Vertragsrechts zulässig (Art. 20, 100, 101 Abs. 3 OR und **Art. 27 ZGB**), insbesondere aber nicht ein Haftungsausschluss für Personenschäden,²⁴ weshalb sich dadurch das Problem auf Sachschäden reduziert.²⁵ **10**

Erfolgt die Freizeichnung in sog. «Allgemeinen Vertragsbedingungen» und ist zweifelhaft, ob die Parteien auch die deliktische Haftung haben ausschliessen wollen, so ist im Rahmen der Auslegungsregel «in dubio contra stipulatorem» nur Freizeichnung für die vertraglichen Schadenersatzansprüche anzunehmen.²⁶ **11**

Durch wirksamen Haftungsausschluss entsteht keine Haftung. Im Kontext mit anderen Haftpflichtigen kann es zu einem sog. «gestörten Solidarschuldnerausgleich» kommen, bei dem fraglich ist, «ob sich der (von Anfang an) befreite Schuldner im Verhältnis zu seinen **[Seite 88]** Mitschuldnern auf die Befreiung berufen kann oder ob ungeachtet der Befreiung im Aussenverhältnis der Regress zu ermöglichen ist».²⁷ **12**

D. Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspruch

Zum Verhältnis zwischen einem Anspruch auf Schadenersatz nach **Art. 41 Abs. 1 OR** wegen Persönlichkeitsverletzung und dem Gewinnherausgabeanspruch nach Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag vgl. **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2b**. **13**

II. Voraussetzungen der ausservertraglichen Verschuldenshaftung

A. Anspruchsvoraussetzungen im Überblick

Bei der Verschuldenshaftung nach **Art. 41 Abs. 1 OR** müssen folgende vier Voraussetzungen **kumulativ** erfüllt sein: **14**

- ein Vermögensschaden (N 15 ff.),
- eine unerlaubte, d.h. widerrechtliche Handlung (N 58 ff.),
- ein (natürlicher und adäquater) Kausalzusammenhang zwischen der schuldhaften Handlung und dem Schaden (N 130 ff.) und
- ein Verschulden des Urhebers (N 151 ff.).²⁸

Aus **Art. 8 ZGB** ergibt sich, dass alle vier Elemente vom Geschädigten zu beweisen sind.

B. Schaden im Rechtssinne

1. Allgemeines

Primäre Voraussetzung eines haftpflichtrechtlichen Schadenersatzanspruches ist die Existenz eines Vermögensschadens; er ist conditio sine qua non der Haftpflicht – **15**

ohne Vermögensschaden keine Haftpflicht.²⁹

[Seite 89] Trotz dieser zentralen Bedeutung hat der schweizerische (wie auch der deutsche) Gesetzgeber darauf verzichtet, den ersatzfähigen Schaden zu definieren;³⁰ das OR setzt den Schadensbegriff voraus³¹ und gibt nur einzelne Anhaltspunkte, welche Positionen als Schaden in Betracht kommen.³² Trotzdem herrscht über den Schadensbegriff sowohl in der Lehre als auch in der Rechtsprechung eine erstaunliche Konstanz, weshalb mindestens hinsichtlich des Kerns des Begriffes Einigkeit besteht.

2. Herrschender, klassischer Schadensbegriff

Differenztheorie: Nach herrschendem klassischem Verständnis ist Schaden im rechtlichen Sinne eine **unfreiwillige und damit ungewollte**³³ 16

Vermögensverminderung (sog. «damnum emergens») oder ein **unfreiwillig entgangener Gewinn** (lucrum cessans). Zum Vermögen gehören dabei einzig die wirtschaftlich «messbaren Güter, an denen eine Person berechtigt ist»,³⁴ während «die Beeinträchtigung persönlich-ideeller Rechtsgüter an sich keinen (Vermögens-)Schaden darstellt [...]. Schaden im Rechtssinne ist [somit] die Differenz zwischen dem gegenwärtigen, nach dem schädigenden Ereignis festgestellten Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte [...] bzw. den Einkünften, die nach dem schädigenden Ereignis tatsächlich erzielt worden sind und denjenigen, die [der geschädigten Person] ohne dieses Ereignis zugeflossen wären» (sog. «**Differenztheorie**»)³⁵ M.a.W.: Schaden ist die ungewollte Verminderung des Reinvermögens. Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in einem entgangenen Gewinn bestehen.³⁶

Gesamtvermögensvergleich: Die Schadenskonzeption der Differenztheorie mit dem Vergleich von zwei Vermögensständen, d.h. eines Gesamtvermögensvergleichs, wird in der Praxis jedoch insofern relativiert, als nicht zwei Gesamtvermögensstände (vor und nach dem schädigenden Ereignis) verglichen werden, sondern nur der konkrete Verlust ermittelt wird, d.h. «es wird untersucht, welche Aktiven durch das schädigende Ereignis weggefallen [Seite 90] oder vermindert und welche Passiven dazugekommen oder vergrößert worden sind» (vgl. auch Art. 42 OR N 19).³⁷ Diese richtige Erkenntnis ist allerdings insofern zu ergänzen, als der «konkrete Verlust»³⁸ unter Einbezug seiner Interdependenzen zu anderen Vermögensbestandteilen ermittelt werden muss.³⁹ 18

Ökonomischer Schadensbegriff und Affektionswert: Mit diesem klassischen, auf der Differenztheorie basierenden Schadensbegriff geht das OR von einem «**ökonomischen Schadensbegriff**» aus,⁴⁰ d.h., der Schaden erhält dadurch einen «finanziellen Charakter».⁴¹ Faktische Nachteile sind deshalb nur insoweit relevant, als sie sich in einer Vermögensverminderung manifestieren,⁴² weshalb Schadenersatzansprüche für die **Beeinträchtigung von Affektionswerten** mangels finanzieller Nachteile ausgeschlossen sind.⁴³ 19

Subjektiv-konkrete Verhältnisse: Konsequenz dieses klassischen Schadensbegriffs ist auch, dass auf die subjektiv-konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschädigten abgestellt wird (zur Auswirkung auf die Schadensberechnung vgl. Art. 42 OR N 20 und 22 ff.). Dieses Schadensverständnis schliesst auch aus, dass dem Geschädigten ein höherer Betrag als der erlittene Schaden ersetzt wird (vgl. zum Bereicherungsverbot Art. 42 OR N 43 ff.).⁴⁴ 20

Der geltende «ökonomische Schadensbegriff» (vgl. N 19) schliesst auch aus, dass bspw. bereits eine Körperverletzung per se als Schaden qualifiziert wird,⁴⁵ erst der als Folge einer Körperverletzung resultierende Vermögensschaden (z.B. 21

Heilungskosten), d.h. die finanzielle Folge (vgl. N 46), ist haftpflichtrechtlich relevant.

Kind als «Schaden»: Die rein finanzielle, ökonomische Ausrichtung des Schadensbegriffs wirkt sich auch in der strittigen Frage aus, ob **ein unerwünschtes Kind** resp. die daraus resultierenden Unterhaltskosten ein rechtlich relevanter Vermögensschaden darstelle. Im Zusammenhang mit der Problematik einer vertraglichen Haftung entschied das BGer in einem grundlegenden Urteil, dass die **Unterhaltskosten** eines ungeplanten – gesunden oder behinderten – Kindes aufgrund einer fehlgeschlagenen bzw. vertragswidrig unterlassenen Sterilisation als Schaden i.S.d. Haftungsrechtes zu qualifizieren seien.⁴⁶ Dieser im Rahmen [Seite 91] eines vertragsrechtlichen Problems aufgestellte Grundsatz hat generelle Bedeutung, d.h. auch für das ausservertragliche Haftpflichtrecht.⁴⁷ 22

Schadenszins: Zum Schaden gehört auch der **Schadenszins** ab dem Zeitpunkt, in dem sich das schädigende Ereignis wirtschaftlich/finanziell ausgewirkt hat (vgl. zu den Details Art. 42 OR N 53 ff.). 23

Nutzungsausfall: Konkret anfallende Kosten als Folge eines Nutzungsausfalles (z.B. für ein Ersatzfahrzeug) gelten als vom klassischen Schadensbegriff erfasster und zu ersetzender Schaden.⁴⁸ Zur Kontroverse über die Frage, ob zwischen wirtschaftlichem und bloss persönlichem Gebrauch zu differenzieren ist, vgl. Art. 42 OR N 37. Zum abstrakten Nutzungsausfall vgl. die Ausführungen zum Kommerzialisierungsschaden N 29 ff. 24

«perte d'une chance»: Nach der aus dem französischen Recht stammende Theorie der entgangenen Chance ist der «Verlust einer blossen Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu vermeiden, als Schaden» zu qualifizieren.⁴⁹ Das BGer lehnt diese Theorie mit der Begründung ab, sie sei einerseits mit der natürlichen Kausalität nicht zu vereinbaren und andererseits bilde der Verlust einer Chance keinen Vermögensbestandteil und könne deshalb **nicht von der Differenztheorie erfasst werden**.⁵⁰ 25

3. Wertende Korrekturen der Differenztheorie

3.1 Ausgangspunkt

Es gibt Situationen, in denen bei der Schadensermittlung mittels Differenztheorie **kein Schaden** entsteht, d.h. keine Vermögensdifferenz festzustellen ist, jedoch unter Wertungsgesichtspunkten gewisse Nachteile ausgeglichen werden sollten.⁵¹ Da der zu ersetzende Schaden hier einzig aufgrund normativer Kriterien festgestellt wird, spricht man vom «**normativen Schaden**» bzw. «**normativem Schadensbegriff**», mit dem die Differenztheorie **wertend** konkretisiert oder korrigiert wird.⁵² 26

[Seite 92] 3.2 Normativer Schaden

Als Folge entsprechender Gesetzesbestimmungen und als Folge der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind folgende normative Schäden anerkannt.⁵³ 27

- **Haushaltsschaden**⁵⁴ (vgl. Art. 42 OR N 41) sowie der gleichzustellende **Pflegeschieden**, wenn der Geschädigte unentgeltlich zuhause von Familienangehörigen gepflegt wird,⁵⁵
- **Beschädigung von Bäumen**⁵⁶ (vgl. Art. 42 OR N 40),
- **Affektionswert bei Verletzung oder Tötung eines Tieres** in besonderen Fällen gem. Art. 43 Abs. 1^{bis} OR (vgl. Art. 43 OR N 24).

Der Begriff des normativen Schadens fand über den sog. «Haushaltsschadenentscheid» des BGer Eingang in die schweizerische Literatur und wurde wohlwollend aufgenommen,⁵⁷ nicht zuletzt mit dem Argument, dass die Rechtsprechung «hier «faute de mieux» richtigerweise der Billigkeit dieser Lösung 28

den Vorrang gegenüber rechtspolitischen Bedenken gewählt» habe.⁵⁸ FELLMANN/KOTTMANN weisen aber mit ihrer fulminanten Kritik – unter Beizug der Kritik am Schadensbegriff im Herkunftsland (Deutschland) – mit bemerkenswerten Argumenten nach, dass der Begriff des normativen Schadens eine blosse Leerformel ist und das BGer «zur **dogmatischen Begründung des Haushaltschadens eine Leerformel** importiert» habe, obwohl der Begriff längst als Schlagwort entlarvt worden sei.⁵⁹ Alles wurde – auch durch die Lehre – «in den »Eintopf« des »normativen Schadens« geworfen, »was mit der Differenztheorie nicht mehr erklärt werden« könne. Teilweise werde das »Begründungsdefizit sogar zum Wesen des normativen Schadensbegriffs« gemacht.⁶⁰ Die Differenzhypothese sei aber auch heute noch im Grundsatz die richtige Methode der Schadensermittlung. Abweichungen davon seien aber nur in offener Begründung vorzunehmen. Beim Haushalt- und beim Pflege- und Betreuungsschaden solle deshalb der Grundsatz »nicht durch einen Hinweis auf eine irgendwie geartete Normativität dieses Schadens gerechtfertigt werden«. Zutreffender sei vielmehr die Überlegung, dass der Geschädigte das Recht zur Einstellung einer Ersatzhaft und zur Geltendmachung der dadurch entstandenen bzw. künftigen Auslagen gehabt hätte. Verzichte er aber darauf, so dürfe der Haftpflichtige davon nicht profitieren.⁶¹

[Seite 93] 3.3 Kommerzialisierungs- und Frustrationsschaden

a) Allgemeines

Durch die Anerkennung der Kommerzialisierungs- und Frustrationsschäden würde die dem klassischen Schadensbegriff zugrunde liegende Differenztheorie wertend, d.h. normativ ergänzt,⁶² wodurch die ausservertragliche Haftpflicht ausgeweitet würde.⁶³ 29

b) Kommerzialisierungsschaden

«Als Kommerzialisierungsschaden wird die durch das schädigende Ereignis verursachte Beeinträchtigung (oder der Verlust) von **entgeltlich erworbenen Nutzungsmöglichkeiten** bezeichnet.»⁶⁴ Es geht also um die Frage, ob ein Schaden eintritt, wenn jemand während einer gewissen Zeit eine ihm gehörende Sache nicht nutzen kann.⁶⁵ Beispiele hierfür sind entgangene Ausritte, weil das Pferd verletzt wurde, oder die entgangene Nutzung einer Mietsache wegen Verletzung des Mieters.⁶⁶ 30

Entscheidend ist in dieser Frage, ob der beeinträchtigte Nutzen gegen Geld im wirtschaftlichen Verkehr erworben werden kann, unabhängig davon, ob der Betroffene das Nutzungsobjekt selbst gekauft oder unentgeltlich erhalten hat, weshalb massgebend ist, ob das Nutzungsobjekt im Veräusserungsfall einen Geldwert aufweist.⁶⁷ 31

Im Kern geht es um die Frage, ob auch ein bloss **abstrakter Nutzungsausfall**, der bei der betroffenen Person nicht zu einem Vermögensschaden führt, weil bspw. für die Reparaturzeit eines beschädigten Autos kein Ersatzwagen gemietet wird, zu einem ersatzfähigen (normativen) Schaden führt.⁶⁸ 32

Die Rechtsprechung hat mit Zustimmung eines Teils der Lehre die Ersatzfähigkeit der Kommerzialisierungsschäden, d.h. die Ersatzfähigkeit des abstrakten Nutzungsausfalles, abgelehnt.⁶⁹ 33

[Seite 94] Eine differenzierende Lösung vertritt REY durch Anwendung des »ökonomisch strukturierten Schadensbegriffs«.⁷⁰ Dadurch kann **ausnahmsweise** von einem Kommerzialisierungsschaden als ersatzfähigem Vermögensschaden gesprochen werden, »wenn 34

- der beeinträchtigte oder verlorene Nutzen in den **Kaufpreis** des Nutzungsträgers **einbezogen** wurde,

- der Betroffene in **besonderem Masse** auf den Gebrauch des Nutzungsobjekts angewiesen ist,
- die **ständige Verfügbarkeit** zum Gebrauch als ein **zentraler Posten im Gesamtvermögen** der eigenen Wirtschaftsführung des Betroffenen gilt». ⁷¹

Nach dem Verständnis dieses «ökonomisch strukturierten Schadensbegriffs» besitzen Gebrauchsgüter mit wirtschaftlichem Wert, bei denen die Gebrauchsmöglichkeiten bereits in den Marktpreis eines Nutzungsträgers einbezogen sind, «Vermögensqualität, so dass bereits die Beeinträchtigung der abstrakten Gebrauchsmöglichkeit zu Schadenersatz führt». ⁷²

35

c) Frustrationsschaden

Während es beim Kommerzialisierungsschaden um den Verlust von entgeltlich erworbenen Nutzungsmöglichkeiten geht (vgl. N 30 ff.), sollen nach dem Frustrationsgedanken zwar nicht abstrakte Nutzungsmöglichkeiten, jedoch jene Aufwendungen schadenersatzfähig sein, die in Erwartung eines zukünftigen Genusses getätigt wurden, sich jedoch im Nachhinein wegen eines schädigenden Ereignisses als nutzlos erweisen (klassisches Beispiel: Theaterbillet verfällt, weil der Theaterbesucher aufgrund eines Unfalls die Vorstellung versäumt). ⁷³ Ein **Frustrationsschaden** liegt somit vor, wenn durch das schädigende Ereignis die Nutzung eines **bereits** bezahlten Aufwandes vereitelt wird, d.h. der finanzielle Aufwand «für die Katz» gewesen ist. ⁷⁴

36

Der überwiegende Teil der Lehre sowie der Rechtsprechung qualifizieren den Frustrationsschaden nicht als Vermögensschaden im Sinne des klassischen auf der Differenztheorie basierenden Schadensbegriffs. Die Aufwendungen seien **vor** dem Schadensereignis getätigt worden und somit nicht Folge des Schadensereignisses, zudem seien sie **freiwillig**, was die Voraussetzung der unfreiwilligen Vermögenseinbusse nicht erfülle. Den nutzlosen Aufwen **[Seite 95]** dungen wird dadurch die Schadensqualität abgesprochen und sie als **nicht ersatzfähig** erklärt. ⁷⁵

37

So einhellig die Ablehnung der nutzlos gewordenen freiwilligen Aufwendungen, d.h. des Frustrationsschadens als ersatzfähiger Schaden, auch erfolgt, so sehr unterliegt diese Meinung erheblichen Zweifeln. Eine prinzipielle Ablehnung des Frustrationsgedankens widerspricht nämlich dem Gesetz, welches selbst nutzlos gewordene Aufwendungen als Vermögensschaden anerkennt, so in Art. 8 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1, Art. 39 Abs. 1, Art. 109 Abs. 2, Art. 195 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 208 Abs. 2, Art. 404 Abs. 2 sowie **Art. 475 Abs. 2 OR**. ⁷⁶ Für HONSELL/ISENRING/KESSLER sind diese Regelungen für den Ersatz frustrierter Aufwendungen im ausservertraglichen Haftpflichtrecht irrelevant, handle es sich doch hier um den «Ersatz frustrierter Aufwendungen im **Vertragsrecht** als negatives Interesse». Dieser Ersatz verstosse keineswegs gegen die Differenzhypothese, da beim negativen Interesse der Geschädigte so gestellt werde, wie wenn der Vertrag nie abgeschlossen worden wäre. ⁷⁷ Gegen die Heranziehung dieser Normen zur gesetzlichen Bestätigung der Frustrierungslehre wird auch angeführt, es handle sich hier immer um Fälle, in denen «der Ersatzberechtigte durch einen vom Ersatzpflichtigen geschaffenen Vertrauenstatbestand zu den Aufwendungen veranlasst worden» sei, «was aber bei rein deliktischer Schädigung nicht» vorliege. ⁷⁸ Dieser Einwand vermag die hier vertretene Auffassung nicht zu widerlegen. Es ist zwar richtig, dass sich die erwähnten Normen innerhalb des Vertragsrechtes befinden. Dass der Ausgleich hier im Rahmen des Vertragsrechtes erfolgt, ist indessen nur insoweit von Belang, als sich daraus ein spezieller – tatbestandlicher – Anknüpfungspunkt für eine spezifisch ausgestaltete Haftung ergibt. Qualitativ beschlagen diese Normen aber allesamt den Ausgleich eines bestimmten vergeblich gewordenen Aufwands. Im Rahmen dieser qualitativen Betrachtungsweise darf es aber keinen Unterschied machen, ob der nachträglich nutzlos gewordene Aufwand Folge einer vorhergehenden Vertrauensserweckung des nachmaligen Ersatzpflichtigen ist oder ob

38

ein Aufwand nicht drittbezogen getätigt, aber wegen eines widerrechtlichen und adäquaten Eingriffs in die Sphäre des Vermögensträgers nachträglich nutzlos wird.

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anerkennung von nutzlos gewordenen freiwilligen Aufwendungen als ersatzfähigem Schaden (vgl. N 38) sowie unter Berücksichtigung des letztlich bereits geltenden «teilweise ökonomisch strukturierten Schadensbegriffs» (vgl. vorne N 19)⁷⁹ ist der sog. «Frustrationsschaden» als ersatzfähig zu qualifizieren, sofern es sich um «ganz **konkrete Aufwendungen für einmalige, temporäre Veranstaltungen**, [Seite 96] z.B. für Theater- und Konzertbesuche oder Sportveranstaltungen» handelt,⁸⁰ aber auch die Aufwendungen für vereitelte Ferien, und zwar unabhängig davon, ob sie nachgeholt werden.⁸¹ Betreffen die Aufwendungen hingegen «allgemeine, für private Zwecke getätigte Investitionen», die durch ein schädigendes Ereignis nutzlos werden, so handelt es sich um solche, die zum allgemeinen Lebensrisiko eines Geschädigten gehören und nicht ersatzfähig sind.⁸²

4. Schadensarten

4.1 «Damnum emergens»/«lucrum cessans»

Zu «damnum emergens» und «lucrum cessans» vgl. vorne N 17. Zur Problematik der «perte d'une chance» im Rahmen eines entgangenen Gewinns vgl. vorne N 25.

4.2 Unmittelbarer und mittelbarer Schaden

Der **mittelbare** Schaden ist zu unterscheiden vom indirekten (Reflex-)Schaden (vgl. Vor Art. 41–61 OR N 51). Als mittelbare Schäden gelten weitere adäquat kausale Folgen des schädigenden Ereignisses, wie besondere Umtriebe, Aufwendungen zur Schadensbegrenzung, zur Beweissicherung, für Sicherungs- und Rettungsmassnahmen, Umschuldungskosten etc., soweit sie aus damaliger Sicht vernünftig waren, Anwalts- und vorprozessuale Parteikosten, sowie seit geboten und angemessen sind⁸³ und nicht durch das Prozessrecht abgedeckt werden.⁸⁴ Eigentliche Prozesskosten sind nicht mittelbarer Schaden, sondern nach anwendbarem Prozessrecht zu beurteilen. Ausnahme: Die schädigende Handlung besteht gerade in widerrechtlicher Ausübung von Verfahrensrechten.⁸⁵ Mittelbarer Schaden liegt u.a. vor, wenn eine verletzte Person erwerbsunfähig wird oder im Rahmen einer Heilbehandlung eine weitere Verletzung mit Schadensfolgen erleidet.⁸⁶ Entgangener Gewinn ist, sofern er durch das schädigende Ereignis adäquat kausal verursacht wurde, mittelbarer Schaden.⁸⁷

Mittelbarer Schaden ist auch gegeben, wenn durch das schädigende Ereignis eine Handlung verhindert wird, die gerade einen Schadenseintritt hätte verhindern können.⁸⁸

[Seite 97] Da sich die Unterscheidung zwischen mittelbarem und unmittelbarem Schaden anhand der Stellung in der relevanten Kausalkette bestimmt, liegt **unmittelbarer Schaden** immer dann vor, wenn sich der Schaden unmittelbar an das schädigende Ereignis anschliesst.⁸⁹

Im ausservertraglichen Haftpflichtrecht wird zwischen dem unmittelbaren und dem mittelbaren Schaden nicht unterschieden.⁹⁰ Der Schädiger haftet für beide Schadensarten, sofern die Voraussetzung der Adäquanz erfüllt ist.⁹¹ Verschieden ist die Regelung z.T. im Vertragsrecht, bspw. Art. 195, 208 oder 357 OR.

Nach Art des verletzten Rechtsgutes wird unterschieden zwischen Personenschaden (N 46), Sachschaden (N 47 ff.) und sonstigem Vermögensschaden (N 53).⁹² Die Aufteilung des Schadensbegriffs in **Personen-, Sach- oder sonstigen Vermögensschaden** ist insb. bedeutsam für die Schadensberechnungsmethoden.⁹³ Die Unterscheidung hinsichtlich der Schadensarten spielt ebenfalls im Versicherungsrecht und bei der Haftung des Motorfahrzeughalters (Art. 58 Abs. 1

SVG [Haftung nur für Personen- und Sachschaden, vgl. N 46–52]) eine bedeutende Rolle.⁹⁴

4.3 Personenschaden

Personenschaden ist jener wirtschaftliche Nachteil, der infolge Tötung oder Verletzung eines Menschen entsteht. Dazu gehören sämtliche Kosten, namentlich diejenigen der Behandlung (damnum emergens), der entgangene Erwerb (lucrum cessans) oder andere, infolge Arbeitsunfähigkeit und Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens eintretende Verluste (vgl. Art. 45 und 46 OR). Zur Berechnung von Personenschäden vgl. **Art. 42 OR** N 16 ff., insb. N 25–27. Beachte: Die Körperverletzung oder Tötung an sich sind noch kein Schaden im Rechtssinne, sondern es sind allein die wirtschaftlichen Nachteile zu ersetzen, welche die Verletzung für den Geschädigten zur Folge hat (vgl. auch **Art. 46 OR** N 11).⁹⁵ Auch der sog. «Haushaltschaden» (vgl. N 28 und **Art. 46 OR** N 69 ff.) ist ein Personenschaden, entsteht er doch als Folge einer Tötung oder Verletzung der haushaltsführenden Person.⁹⁶ 46

[Seite 98] 4.4 Sachschaden

Sachschaden ist der aus der Beschädigung, der Zerstörung oder dem Verlust einer Sache resultierende Vermögensschaden,⁹⁷ bspw. Reparaturkosten, Minderwert einer Sache.⁹⁸ Dazu gehören auch die sog. «Folgeschäden» wie z.B. Entsorgungsaufwand,⁹⁹ ebenso die Kosten für die vorübergehende Benutzung eines Ersatzgegenstandes.¹⁰⁰ 47

Ungeklärt ist die Frage, wann eine Sache als beschädigt gilt und deshalb ein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden vorliegt. Ist dies nur der Fall, wenn die Sachsubstanz beeinträchtigt ist,¹⁰¹ oder auch schon in jenen Fällen, in denen lediglich die Funktion der Sache beeinträchtigt ist, bspw. wenn ein für Materialtransporte verwendetes Motorschiff an der Ladestelle verbleiben muss, weil die Zu- bzw. Wegfahrtswasserstrasse während längerer Zeit unpassierbar ist.¹⁰² Das entscheidende Problem in dieser Frage ist: Wenn eine Vermögenseinbusse, die durch blosse Funktionsbeeinträchtigung einer Sache entstanden ist, als relevanter Schaden qualifiziert werden soll, «so sind Kriterien erforderlich, aufgrund dieser eine derartige «reine» Nutzungsbeeinträchtigung als haftpflichtrelevante Eigentumsverletzung qualifiziert werden kann»,¹⁰³ was gerade das zu lösende Problem darstellt. 48

Sowohl die Zerstörung, die Beschädigung als auch der Verlust der Sache (sowie allenfalls die Funktionsbeeinträchtigung, vgl. N 48) an sich stellen nicht den Sachschaden dar, sondern einzig dessen Ursache. Massgebend ist die daraus unfreiwillig eintretende Vermögenseinbusse (vgl. bereits vorne N 17).¹⁰⁴ 49

Umstritten ist, ob die Unterbrechung oder Löschung elektronischer Daten einer Datenverarbeitungsanlage einen Sachschaden darstelle. Abhängig ist diese Frage davon, ob der Datenbestand im Trägermaterial verkörpert ist bzw. vom Sachbegriff.¹⁰⁵ 50

[Seite 99] Wertminderungen einer Sache ohne dass die Substanz beeinträchtigt wird, gelten als reine Vermögensschäden (vgl. hinten N 53 ff.).¹⁰⁶ 51

Zur Schadensberechnung bei Sachschaden vgl. die Kommentierung zu **Art. 42 OR**. 52

4.5 Sonstiger und reiner Vermögensschaden

Sonstiger Vermögensschaden ist jeder andere Schaden i.S.v. N 17 ff., der eine Person trifft, ohne dass er Folge einer Tötung oder Körperverletzung oder Folge einer Beschädigung, Zerstörung oder eines Verlusts einer Sache ist.¹⁰⁷ Diese sonstigen Vermögensschäden resultieren meist aus der Verletzung von 53

Patentrechten, Markenrechten oder aus unlauterem Wettbewerb oder aber aus der Verletzung einer sog. «Schutznorm» (vgl. hierzu N 63 und 67 ff.).¹⁰⁸

Reine Vermögensschäden sind jene Schäden, die nicht Folge einer der vorstehend genannten Rechtsverletzungen, d.h. tatbestandsmässigen Handlungen, sind, weshalb sie nicht ersatzfähig sind.¹⁰⁹ **54**

Die sog. «sonstigen Vermögensschäden» im Sinne von N 53 sind jeweils dort ersatzpflichtig, wo eine Haftungsnorm allgemein von Schaden spricht, nicht aber z.B. bei **Art. 27 EleG**, Art. 40b ff. EBG, **Art. 64 LFG** und **Art. 58 Abs. 1 SVG**, wo ausdrücklich nur von Personen- und Sachschaden die Rede ist.¹¹⁰ **55**

4.6 Direkter und indirekter Schaden/Reflex- und Drittschaden

Bei der Unterscheidung zwischen direktem/indirektem und Reflex-/Drittschaden geht es nicht um Schadensarten, sondern um die Person des Geschädigten bzw. um seine Anspruchsberechtigung/Aktivlegitimation (vgl. Vor **Art. 41–61 OR** N 44 ff., insb. N 46 i.V.m. 51 f.). **56**

[Seite 100] 4.7 Schockschäden Dritter

Auch die Schockschäden Dritter sind nicht ein Problem des Schadensbegriffs oder eine besondere Schadensart. Die zentrale Frage ist hier ebenfalls die Anspruchsberechtigung der geschädigten Drittperson (vgl. Vor **Art. 41–61 OR** N 48 f.). **57**

C. Widerrechtlichkeit

1. Allgemeines

1.1 Bedeutung und Funktion der Widerrechtlichkeit

Neben der Existenz eines Vermögensschadens (vgl. N 15 ff.) ist weitere Voraussetzung einer ausservertraglichen Haftung das Vorliegen einer sog. «Widerrechtlichkeit», und zwar beim Vermögensgeschädigten (**Kumulation von Schaden und Widerrechtlichkeit**; vgl. N 14). **58**

Die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit gilt nach h.M. sowohl für **Schadenersatz-** als auch für **Genugtuungsansprüche**, und zwar sowohl bei den **Verschuldens-** als auch den **Kausalhaftungen** (inkl. Gefährdungshaftungen), obwohl die Widerrechtlichkeit bei den verschuldensunabhängigen Haftungen nicht expressis verbis verlangt wird.¹¹¹ **59**

Sowohl Lehre als auch Rechtsprechung betonen, dass die Voraussetzung der Widerrechtlichkeit die **Funktion einer Haftungsbegrenzung** besitze, um mit ihr schadenersatzrechtlich relevante Schädigungen von hinzunehmenden Nachteilen zu unterscheiden.¹¹² **60**

Der Gesetzgeber hat es – wie beim Schadensbegriff (vgl. vorne N 16) – unterlassen, die Haftungsvoraussetzung «Widerrechtlichkeit» zu definieren. Die Begriffsbestimmung war damit der Wissenschaft und der Praxis überlassen.¹¹³ **61**

[Seite 101] 1.2 Widerrechtlichkeitstheorien

a) Objektive Widerrechtlichkeitstheorie

Im Gegensatz zur Wissenschaft, in der der Theoriestreit immer noch anhält,¹¹⁴ vertritt das BGer in selten konstanter Praxis die sog. «objektive **62**

Widerrechtlichkeitstheorie» als der Generalnorm von **Art. 41 Abs. 1 OR** zugrunde liegend, was die traditionelle Lehre unterstützt.¹¹⁵

Nach dem in der deutschen Pandektistik im 19. Jahrhundert entwickelten **objektiven Widerrechtlichkeitsbegriff**¹¹⁶ ist eine Schadenszufügung dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine **allgemeine gesetzliche Pflicht** verstösst, indem entweder

- ein **absolutes Recht** des Geschädigten verletzt wird (sog. «Erfolgsunrecht»), oder
- eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine **einschlägige Schutznorm** bewirkt wird (sog. «Verhaltensunrecht»).

Die Widerrechtlichkeit erscheint somit bei der objektiven Theorie in **zwei Formen**. Einerseits als sog. «**Erfolgsunrecht**» bei Verstoss gegen ein absolutes Recht (vgl. N 64 ff.) des Geschädigten, andererseits als «**Verhaltensunrecht**» (vgl. N 67 ff.) als Folge einer besonderen Schutznorm.

Absolute Rechte sind: Leib, Leben, körperliche, seelische und geistige Integrität, Persönlichkeit, Eigentum, Besitz, die beschränkten dinglichen Rechte und Immaterialgüterrechte.¹²⁰

[Seite 102] Umstritten ist im Rahmen der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie die Frage, ob **Treu und Glauben** i.S.v. **Art. 2 ZGB** zu den absoluten Rechtsgütern gehört (vgl. hinten N 92 ff.).¹²¹

Kein absolutes Rechtsgut ist nach anerkannter Meinung das **Vermögen als solches**¹²² und ebenso wenig relative Rechte gegenüber Drittpersonen.¹²³

(Vermögens-)Schutznorm: Schutznorm im Sinne des ausservertraglichen Haftpflichtrechts ist eine «**Verhaltensnorm, die den Schutz vor Schäden von der Art des eingetretenen bewirkt**».¹²⁴ Eine Schutznorm dient dazu, in jenen Fällen, in denen ein Vermögensschaden, ohne Verletzung eines absoluten Rechtsgutes eintritt, zu eruieren, ob er trotzdem ersatzfähig ist oder nicht.

Hat eine Norm einen ausschliesslich anderen Zweck als die Verhinderung von Vermögensschäden, wie sie im konkreten Fall eingetreten sind, liegt keine Widerrechtlichkeit vor, da der Schaden nicht vom Schutzbereich der Norm erfasst wird;¹²⁵ damit liegt auch kein Verhaltensunrecht vor.¹²⁶ Die Schutznorm muss auch einen genügenden Grad an Bestimmtheit aufweisen.¹²⁷

Vermögensschutznormen finden sich in der ganzen Rechtsordnung; es kann sich um geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handeln.¹²⁸ Widerrechtlichkeit wird vom BGE auch aus der Verletzung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen abgeleitet.¹²⁹

Haftpflichtrechtliche Schutznormen (oder besser Normen mit haftpflichtrechtlichem Schutzzweck), bei deren Verletzung Verhaltensunrecht vorliegt, finden sich vorwiegend im (Vermögens-)Strafrecht.¹³⁰ Die h.L. und die Rechtsprechung verlangen zur Begründung der Widerrechtlichkeit durch Verletzung einer strafrechtlichen Schutznorm sowohl die Erfüllung des objektiven als auch des subjektiven Tatbestandes der Strafnorm.¹³¹ Mit eindrücklichen Argumenten weist jedoch VERDE, Rz 542, darauf hin, dass nicht der Straftatbestand [Seite 103] (und damit die Erfüllung der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale) zur Widerrechtlichkeitsbegründung herangezogen werden dürfen, sondern einzig die im Straftatbestand enthaltene Verhaltensnorm.¹³² Er stellt deshalb zu Recht fest, dass es für die Frage der Widerrechtlichkeit nicht massgebend ist, was der Schädiger beabsichtigte. «Sämtliche Willenskomponenten eines strafatbestandlichen Unrechts sind daher nicht massgebend für die Begründung der Widerrechtlichkeit im Haftpflichtrecht».¹³³

Normen mit haftpflichtrechtlichem Schutzzweck sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung u.a.: **Art. 239 Abs. 2 StGB** (Schutz der Stromabnehmer bei den sog.

«Kabelbruchfällen»);¹³⁴ Art. 305^{bis} StGB (Geldwäscherei).¹³⁵ Zu den weiteren Schadenersatzanspruch zusprechenden oder ablehnenden Urteilen im Zusammenhang mit Schutznormen sowie für eine **Übersicht über weitere Schutznormen** vgl. FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 481 f.; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 35**; sowie REY, Rz 707–709b.

b) Subjektive Widerrechtlichkeitstheorie

Im Gegensatz zur objektiven Theorie, bei der mittels dem Begriff der Widerrechtlichkeit zwischen rechtlich ersatzwürdigen und rechtlich nicht abwälzbaren Schäden unterschieden wird (vgl. vorne N 60), knüpft die wohl als überholt geltende, aber vereinzelt doch wieder vertretene subjektive Widerrechtlichkeitstheorie¹³⁶ an ein **allgemeines Schädigungsverbot** an.¹³⁷ Nach diesem allgemeinen Schädigungsverbot des «neminem laedere» sei es grundsätzlich verboten, einem anderen Schaden zuzufügen. Eine Schädigung eines Dritten sei deshalb nur erlaubt, wenn ein Rechtfertigungsgrund dafür vorliege. Die Widerrechtlichkeit lässt sich nach dieser Theorie als «Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen oder als Fehlen von Widerrechtlichkeitsausschlussgründen» umschreiben.¹³⁸

Die subjektive Widerrechtlichkeitstheorie verlangt folglich ein höchst differenziertes System von Rechtfertigungsgründen, «andernfalls das Haftpflichtrecht mit der sozialen Wirklichkeit in Konflikt geriete».¹³⁹ Das BGer hielt diesbezüglich treffend fest, dass man bei dieser Theorie gezwungen sei, «nach immer neuen Rechtfertigungsgründen zu suchen, soll die allgemeine Deliktshaftung nicht uferlos auswuchern».¹⁴⁰

Der Unterschied zwischen der objektiven und der subjektiven Widerrechtlichkeitstheorie zeigt sich insb. bei den sog. «reinen Vermögensschäden». Diesbezüglich müsste bei der subjektiven Theorie zur Prüfung der Ersatzfähigkeit zwar keine Schutznorm gesucht werden, da der reine Vermögensschaden bereits widerrechtlich ist, jedoch umgekehrt ein Recht **[Seite 104]** Rechtfertigungsgrund. Die Frage bzw. das Werturteil hat sich dabei einzig verschoben, von der Suche nach einer Schutznorm zur Suche eines Rechtfertigungsgrundes.

Verschieden ist bei beiden Theorien auch die Beweislast. Bei der objektiven Theorie trifft den Geschädigten die Beweislast betreffend die Widerrechtlichkeit, den Schädiger hinsichtlich eines Rechtfertigungsgrundes. Bei der subjektiven Theorie muss die Widerrechtlichkeit als vermutet gelten, weshalb den Schädiger die Beweislast hinsichtlich der Rechtfertigung trifft.¹⁴¹ Dies widerspricht jedoch einer freiheitlichen Regelung: Wo die Freiheit vermutet werde, muss nicht ein Schädiger sein Recht beweisen, sondern es liegt am Geschädigten, eine Verbotsverletzung nachzuweisen.¹⁴²

Die subjektive Widerrechtlichkeit konnte sich nie durchsetzen. Argumente dagegen sind: Sie gilt als zu vage, lasse die Position des Geschädigten im Hintergrund,¹⁴³ höhle den Tatbestand der Widerrechtlichkeit aus und erfülle die Funktion der Haftungsbeschränkung zu wenig,¹⁴⁴ bringe keine Verbesserung hinsichtlich des Problems Erfolgsunrecht/Verhaltensunrecht (vgl. hierzu N 80 ff.) und widerspreche unserem Rechtssystem.¹⁴⁵

c) Sog. «dritte Widerrechtlichkeitstheorie»

Zur Überwindung der Schwächen sowohl der objektiven als auch der subjektiven Widerrechtlichkeitstheorie wird seit geraumer Zeit die sog. «dritte Widerrechtlichkeitstheorie» vertreten.¹⁴⁶ Insb. kritisiert wird die Unterscheidung zwischen Erfolgs- und Verhaltensunrecht (vgl. N 63), die Privilegierung der Schäden aus der Verletzung von absoluten Rechten gegenüber reinen Vermögensschäden, sowie die automatische Schlussfolgerung von der Verletzung eines absoluten

Rechtsgutes auf die Widerrechtlichkeit der daraus resultierenden Vermögensschäden.¹⁴⁷

Nach dieser Theorie soll Widerrechtlichkeit völlig losgelöst von der Verletzung von absoluten Rechtsgütern und der «Jagd» nach Schutznormen als **Verletzung einer Verhaltenspflicht** verstanden werden. Es wird zum Teil auch von Verletzung einer Sorgfaltspflicht¹⁴⁸ oder einer Schutzpflicht gesprochen.^{149, 150}

[Seite 105] Auch in der sog. «dritten Widerrechtlichkeitstheorie» wird keine taugliche Alternative zur objektiven Widerrechtlichkeitstheorie (vgl. vorne N 62 ff.) gesehen.¹⁵¹ Gegen diese Theorie wird zum Teil zu Recht angeführt:

1. Die historische Auslegung zeige, dass der Gesetzgeber von der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie ausgegangen sei, insb. beim nachträglich eingefügten Abs. 2, der bei einer Widerrechtlichkeitsdefinition als Verhaltenspflichtverletzung obsolet würde.
2. Ein autonomer Rechtswidrigkeitsbegriff in **Art. 41 Abs. 1 OR** hätte auch eine Spaltung der Rechtswidrigkeit zur Folge (Bsp.: Die mittels eines Motorfahrzeuges zugefügte Körperverletzung könne *strafrechtlich* bspw. durch Notstand/Notwehr gerechtfertigt sein, während *haftpflichtrechtlich* bei Gefährdungshaftungen keine die Haftung ausschliessende Rechtfertigung möglich sein soll).¹⁵²
3. Unhaltbare Konsequenz der Beschränkung auf das Verhaltensunrecht sei auch, dass bei Gefährdungshaftungen die Widerrechtlichkeit keine Haftungsvoraussetzung sein soll.¹⁵³

2. Objektive Widerrechtlichkeitstheorie als (einheitliche) Normwiderrechtlichkeit im Besonderen

2.1 Erfolgsunrecht als Verhaltensunrecht

Nach traditionellem Verständnis in Lehre und Rechtsprechung ist die Verletzung eines absoluten Rechts an sich bereits widerrechtlich; es liegt sog. «Erfolgsunrecht» vor.^{154, 155}

Verschiedenste Abhandlungen zum Widerrechtlichkeitsbegriff, insb. zur Lehre von Erfolgsunrecht, kritisierten die Schwächen dieser Theorie und zeigten auf, wo sie (vermeintlich) versage, nämlich z.B. bei Schädigungen durch **Unterlassungen**. Denn das Urteil über einen Unterlassungsanspruch setze ein Urteil über eine zukünftige Handlung voraus. Dies leiste die Lehre des Erfolgsunrechtes jedoch nicht, denn nach ihr kann ja erst rückblickend – nach Eintritt des Erfolges – die Widerrechtlichkeit festgestellt werden. Deshalb versage diese [Seite 106] Theorie auch in Bezug auf das **Notwehrrecht**, das einen widerrechtlichen Angriff voraussetzt.¹⁵⁶

PORTMANN, dem das Verdienst zukommt, all die Schwächen der Lehre vom Erfolgsunrecht konzipiert zu haben, greift mit seiner Kritik insb. aber das Fundament der Lehre an. Er weist zu Recht darauf hin, dass «ein Erfolg als solcher nicht widerrechtlich» sein kann, sondern einzig ein Verstoss gegen Gebote und Verbote der Rechtsordnung, und dagegen könne nur menschliches Verhalten verstossen.¹⁵⁷ Bereits denklogisch folgt mit PORTMANN, dass «Erfolgsunrecht [...] sich von vornherein nur *als widerrechtliches Herbeiführen eines Erfolges durch menschliches Verhalten*» denkbar sei.¹⁵⁸

Wird aber erkannt, dass widerrechtliches Herbeiführen eines Erfolges nur durch menschliches Verhalten denkbar ist,¹⁵⁹ und wird die Erkenntnis mitberücksichtigt, dass es bei sämtlichen Formen eines absoluten Rechts darum geht, allen zu verbieten, «bestimmte Güter oder Interessen der Berechtigten zu verletzen oder zu gefährden»¹⁶⁰ – Portmann spricht diesbezüglich von «**Verbotsrecht**»¹⁶¹ –, so wird einsichtig, dass ein absolutes Recht dem Berechtigten nicht das Recht gibt, ein an

sich erlaubtes Verhalten zu verbieten, sondern dass Dritten ihm gegenüber ein bestimmtes Verhalten untersagt ist. Das absolute Recht beinhaltet folglich das Recht auf ein bestimmtes Verhalten, weshalb auch **bei den absoluten Rechten sich die Widerrechtlichkeit aus einem Verstoß gegen eine gesetzliche Verhaltensnorm mit Schutzfunktion ergibt**. Folglich ist nicht die Rechtsgutverletzung entscheidend, sondern ob «**eine dem Schutz des Rechtsgutes dienende Verhaltensvorschrift missachtet wurde**».¹⁶² Die **Widerrechtlichkeit liegt somit auch bei der Verletzung absoluter Rechte in der Verletzung von Verhaltensnormen**.

Die in der h.L. und Rechtsprechung erfolgte Gleichsetzung von Verletzung eines absoluten Rechtsgutes mit der Widerrechtlichkeit¹⁶³ basiert letztlich auf einer Verabsolutierung¹⁶⁴ einer Aussage oder auf einem falschen Verständnis von OFTINGER.¹⁶⁵ Basierend auf den Erkenntnissen von MERZ¹⁶⁶ stellte OFTINGER – leider nur in einer Fussnote – ebenfalls fest: [Seite 107] «Die Verletzung eines absoluten Rechts ist genau genommen eine **Reflexwirkung der Verletzung einer Rechtsnorm**.»¹⁶⁷ Und MERZ erkannte schon 1955: «Es geht dabei nur darum im absoluten Recht die mit ihm untrennbar verbundene, an alle **gerichtete Verhaltensvorschrift** des «Du sollst nicht ... **was** (nämlich fremdes Leben und Eigentum, fremde Gesundheit und körperliche Integrität, fremde Persönlichkeitsrechte und immaterielle Güterrechte verletzen)» zu erkennen.»¹⁶⁸ Zweifelsfrei gehen die beiden Autoren auch **bei der Verletzung eines absoluten Rechts** letztlich nicht vom Verletzungserfolg für die Widerrechtlichkeitsbegründung aus, sondern auch hier von der Verletzung einer Verhaltensnorm und damit von **Verhaltensunrecht**.

Das von MERZ vertretene und letztlich von OFTINGER aufgenommene Widerrechtlichkeitsverständnis basierte somit umfassend auf **Verhaltensunrecht**. Während hinsichtlich

- der absoluten Rechtsgüter die Verhaltensvorschrift lautet: «Du sollst nicht [...] **was** verletzen»,¹⁶⁹ lautet die an alle Rechtsgenossen gerichtete Verhaltensvorschrift bei
- Vermögensschäden, die nicht aus der Verletzung absoluter Rechte resultieren, also bei sog. «reinen Vermögensschäden»: «Du sollst nicht [...] **wie** (nämlich durch unlauteren Wettbewerb [...])» jemanden schädigen.¹⁷⁰

Vom selben, letztlich aber zu wenig bewusst gewordenen Widerrechtlichkeitsverständnis betreffend die Verletzung von absoluten Rechten gingen KELLER/GABI auch 1985 aus, indem sie erklärten: «Eine Rechtsgutverletzung reicht [...] nicht aus, um die Widerrechtlichkeit zu begründen. Vielmehr bedarf es in jedem Fall eines Verstoßes gegen eine Norm, welche den Eingriff in ein geschütztes Rechtsgut verbietet [...]»¹⁷¹

Nach Auffassung dieser Autoren lassen sich diese **Verhaltensnormen betreffend absoluter Rechte** auf einen allgemeinen und umfassenden Verhaltenskodex von **fünf Grundschutznormen** zusammenführen, nämlich:

1. das Verbot, jemanden zu töten,
2. das Verbot, jemandes körperliche oder geistig-seelische Integrität zu verletzen,
3. das Verbot, jemandes Persönlichkeit zu verletzen,
4. das Verbot, jemandes Eigentum oder Besitz zu beeinträchtigen (zum Besitz als absolutes Recht vgl. vorne Fn 120)
5. das Verbot, gegen Treu und Glauben (vgl. zur hier festzustellenden Kontroverse vorne N 65) zu handeln.¹⁷²

Eine Rechtsgutverletzung reicht somit auch hier – im Gegensatz zur reinen Lehre des Erfolgsunrechts – nicht aus, um die Widerrechtlichkeit zu begründen. Es braucht immer einen [Seite 108] Verstoß gegen eine Norm, die einen Eingriff in ein geschütztes Rechtsgut verbietet – oder bei sog. «reinen Vermögensschäden» – ein

Verhalten vorschreibt, das einen solchen Eingriff vermeiden soll. Es handelt sich somit um eine (umfassende) **Normwiderrechtlichkeit**.¹⁷³

Sinngemäss geht heute wohl auch REY von einem Verhaltensunrecht bei Verletzung eines absoluten Rechtes aus, wenn er in diesem Zusammenhang expressis verbis auf die den absoluten Rechten entsprechenden Schutznormen verweist.¹⁷⁴ Leider geht auch er verbal immer noch von zwei Widerrechtlichkeitsformen aus (Erfolgsunrecht und Verhaltensunrecht).¹⁷⁵ Dies ist insofern und solange unschädlich, als man sich bewusst ist, dass die Aussage «Erfolgsunrecht» den dahinter stehenden Frageprozess (Du sollst nicht was) quasi elipsenartig verkürzt wiedergibt und in beiden sog. «Widerrechtlichkeitsformen» es sich einzig um Verhaltensunrecht handelt. 89

2.2 Normwiderrechtlichkeit (Verhaltensunrecht) als umfassende Widerrechtlichkeit i.S.v.

Art. 41 Abs. 1 OR

Das absolute Recht beinhaltet – wie dargelegt – nur ein Recht auf ein bestimmtes Verhalten (vgl. vorne N 83). Die Widerrechtlichkeit besteht bei Verletzung absoluter Rechte letztlich auch in der Verletzung einer Verhaltensnorm, weshalb entgegen der Lehre vom Erfolgsunrecht auch hier einzig und nur Verhaltensunrecht vorliegt. 90

Im Kontext der sog. «zweiten Erscheinungsform» einer Widerrechtlichkeit, dem sog. «Verhaltensunrecht» bei Verletzung einer Schutznorm, die gerade den Schutz vor Schäden der eingetretenen Art bezweckt (vgl. vorne N 67), ergibt sich die Konsequenz, dass **Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR umfassend als Verhaltensunrecht zu verstehen ist**, d.h. auf einem objektiven Normverstoss basiert (Normwiderrechtlichkeit). Will man die beiden Erscheinungsformen nicht aufgeben und nicht einheitlich nur von Verhaltensunrecht sprechen, so darf bei Verletzung eines absoluten Rechts nicht automatisch auf Widerrechtlichkeit geschlossen werden, da «nicht jede Rechtsgutverletzung notwendigerweise auf die Verletzung einer Grundschutznorm zurückgeführt werden kann». ¹⁷⁶ Die Verletzung eines absoluten Rechtsgutes ist somit einzig ein höchst gewichtiges Indiz für eine Widerrechtlichkeit. 91

3. Treu und Glauben als absolutes Recht bzw. Grundschutznorm

Umstritten ist die Frage, ob Treu und Glauben i.S.v. **Art. 2 ZGB** zu den absoluten Rechtsgütern gehört (vgl. vorne N 65). Während ein Teil der Lehre und Rechtsprechung dies uneingeschränkt in dem Sinne bejaht, als der Grundsatz von Treu und Glauben eine Grundschutznorm (vgl. vorne N 87) darstellt und damit zu den absoluten Rechtsgütern gehört, deren **[Seite 109]** Verletzung schon per se Widerrechtlichkeit begründet,¹⁷⁷ lehnen andere dies wiederum vollumfänglich ab.¹⁷⁸ Eine dritte Gruppe knüpft an den Wortlaut von **Art. 2 Abs. 1 ZGB** an («Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten [...]») und stellt fest, der Grundsatz beziehe sich auf bereits bestehende Rechte und Pflichten,¹⁷⁹ Treu und Glaube beanspruche deshalb nur Beachtung im Rahmen einer vorbestehenden Sonderverbindung, i.S. eines besonderen Vertrauens- und Treueverhältnisses, woraus die Pflicht zum Handeln nach Treu und Glauben resultiere. 92

Aus den massgebenden BGE, in denen die Widerrechtlichkeit wegen Verletzung von Treu und Glauben (**Art. 2 ZGB**) bejaht wurde, konkretisierte die einschlägige Lehre und Rechtsprechung diese Sonderverbindung i.S. eines besonderen Vertrauens- und Treueverhältnisses¹⁸⁰ durch Bildung von Fallgruppen heraus, nämlich:¹⁸¹ 93

- aufgrund eines prozessualen oder verfahrensrechtlichen Verhältnisses;¹⁸²
- aufgrund eines Vertragsverhandlungsverhältnisses (c.i.c.);¹⁸³

- durch falsche ausservertragliche Auskunft oder Raterteilung,¹⁸⁴
- durch Inverkehrbringen von Urkunden oder anderen Schriftstücken.¹⁸⁵

Die Widerrechtlichkeit eines Verhaltens ist bei Verstoss gegen Treu und Glauben somit nach diesen Meinungen nur gegeben, wenn der Verstoss im Rahmen des vorbestehenden Vertrauens- und Treueverhältnisses einer dieser Fallgruppen erfolgt.

Mit der Voraussetzung einer vorbestehenden «rechtlichen Sonder(ver)bindung i.S. eines vorbestehenden besonderen Vertrauens- und Treueverhältnisses»¹⁸⁶ wird das ausservertragliche Haftpflichtrecht strukturell «verlassen», denn dieses kommt «typischerweise gerade dann zur Anwendung, wenn keine solche Sonderverbindung, sondern ein blosser «Zufallskontakt» vorliegt».¹⁸⁷ Durch die Sonderverbindung «wird die abwehrbereite Isolation, die sich in einem «Nebeneinander» der Rechtskreise widerspiegelt, durch ein «Miteinander» ersetzt».¹⁸⁸

94

[Seite 110] Unrichtige Rat- und Auskunfterteilung im Besonderen. Nebst den Entscheidungen, in denen das BGer die Haftung für falsche freiwillige Rat- und Auskunfterteilung an die Existenz einer vorbestehenden Sonderverbindung i.S. eines Vertrauens- und Treueverhältnisses knüpft (vgl. vorne N 93), verzichtete es wiederum in anderen Urteilen auf die Existenz einer vorbestehenden Sonderverbindung und erfasste die Fälle rein deliktsrechtlich. Aus einem ungeschriebenen «Gebot der allgemeinen Rechtsordnung»¹⁸⁹ bzw. einer «Norm des ungeschriebenen Rechts»¹⁹⁰ bzw. «aus einer allgemeinen verstandenen Loyalitätspflicht und damit letztlich aus Treu und Glauben»¹⁹¹ entwickelte es den Grundsatz, dass Widerrechtlichkeit vorliege, wenn der Auskunft- und Raterteilende

95

- wegen seines Fachwissens beansprucht wird, also «besonderen Einblick in die den Gegenstand der Anfrage bildenden Verhältnisse hat»,¹⁹²
- Auskunft erteilt (oder Gefälligkeiten erbringt),¹⁹³
- ihm die Bedeutung der Antwort für den Fragesteller erkennbar ist, und
- absichtlich oder leichtfertig falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt, deren Richtigkeit oder Kenntnis für den Entscheid des Anfragenden wesentlich sind.¹⁹⁴

Aufgrund dieser Rechtsprechung muss der gegebene Rat oder die Auskunft aufgrund einer ungeschriebenen Verhaltensnorm richtig und vollständig sein, und das objektiv berechnete Vertrauen des Ratsuchenden darf nicht enttäuscht werden, ansonsten Widerrechtlichkeit i.S.v. **Art. 41 Abs. 1 OR** begründet wird.¹⁹⁵ **BGE 124 III 363**, E. 5.b erklärt dementsprechend: «Es erscheint [...] sachgerecht, die Haftung für die falsche Auskunft i.c. deliktsrechtlich [...] zu erfassen [...]» (vertritt aber zusätzlich die Meinung, sie könne auch den Grundsätzen der Vertrauenshaftung bzw. der c.i.c. unterstellt werden).

96

Dogmatisch ist die Beliebigkeit des BGer, mit der es in den letzten Jahren die Zuordnung der Haftung für unrichtigen Rat und Auskunft vornimmt, störend. Dies umso mehr, als mit der Vertrauenshaftung höchststrichterlich eine nicht unumstrittene neue Haftungskategorie geschaffen wurde (vgl. hinten N 108 ff.). Zweifelhaft ist aber auch, zur Begründung der Widerrechtlichkeit bloss «auf eine Norm des ungeschriebenen Rechts [vgl. vorne N 95] zurückzugreifen, die den Wissenden verpflichten sollte, bei Fragen von bedeutender Tragweite richtig zu antworten».¹⁹⁶ Näherliegend und dogmatisch auch begründbar ist, **Art. 2 ZGB** als Grundsatznorm anzuerkennen (zu den Grundsatznormen vgl. vorne N 87). Allerdings ist dabei zu beachten, dass **Art. 2 ZGB** kein «selbständiger Rechtssatz» ist, «der ein bestimmtes Rechtsverhältnis regelt, sondern bloss [sic] eine Rechtsanwendungsnorm, **[Seite 111]** die bei allen Rechtsverhältnissen zu beachten ist».¹⁹⁷ **Art. 2 ZGB** ist als Generalklausel nicht unmittelbar vollziehbar, sondern bedarf der Konkretisierung.¹⁹⁸ Der blosser Hinweis auf **Art. 2 ZGB** genügt nicht. Stets muss das «Warum der Anwendung» festgestellt und die «praktikable Unternorm»

97

gebildet werden.¹⁹⁹ Das Prinzip von Treu und Glauben von Art. 2 ZGB kann dadurch verletzt werden, als ein Verstoss gegen eine Rechtsnorm/Unternorm zugleich ein Verstoss gegen das Prinzip von Treu und Glauben bedeutet.²⁰⁰

In selten konstanter Rechtsprechung vertrat das BGer denn auch (bis zu den Vertrauenshaftungsurteilen) in der Frage der (Dritt)Haftung für falsche freiwillige Auskünfte die Meinung, dass Dritte für falschen freiwilligen Rat und Auskünfte nur über die unerlaubte Handlung i.S.v. Art. 41 ff. OR schadenersatzpflichtig werden können.²⁰¹ Dabei ging das BGer in der Widerrechtlichkeitsfrage nicht von einer vorbestehenden «Parteibeziehung» aus, sondern rügte die direkte Verletzung allgemeiner Pflichten und argumentierte konsequent deliktisch.²⁰² Ausgangspunkt war dabei die aus Art. 2 ZGB fliessende Pflicht, «niemandes Vertrauen zu erwecken und zu täuschen», die schon «besteht, bevor irgendein Inbeziehungtreten zweier Parteien erfolgt».²⁰³

Zur Vermeidung einer allgemeinen Informations- und Wahrheitspflicht als Konsequenz der Pflicht «niemandes Vertrauen zu erwecken und zu täuschen», verlangt das BGer berechtigtes Vertrauen zur materiellen Bestimmung und Begrenzung des Vertrauenstatbestandes. Dieses liegt nur dann vor, wenn das Vertrauen «in einer Autorität erfolgt und das Verhalten des Geschädigten selbst vor den Massstäben von Treu und Glauben stand hält».²⁰⁴

Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR ergibt sich somit durch Verstoss gegen Treu und Glauben infolge «Erweckung und Täuschung berechtigten Vertrauens» (Unternorm).²⁰⁵ Berechtigtes Vertrauen liegt dann vor, «wenn aufgrund der Einlassung einer Autorität auf eine Antwort überhaupt auf die Sachkompetenz des Auskunftgebenden und dessen loyales Verhalten unter Berücksichtigung der für den Auskunftverlangenden ebenfalls geltenden Redlichkeitsanforderungen vertraut wird, sofern für den Auskunftgebenden erkennbarermassen vermögensrechtliche Dispositionen auf dem Spiele stehen».²⁰⁶

Die Haftung für falschen freiwilligen Rat erweist sich dadurch als ein Anwendungsfall von Art. 2 ZGB und eines damit verbundenen ausservertraglichen Vertrauensschutzes²⁰⁷ mit der Folge, «dass unter klar definierten Voraussetzungen auf indirektem Wege eine Art «Ver [Seite 112] kehrspflichten zum Schutze fremden Vermögens» existieren».²⁰⁸ Das Prinzip von Treu und Glauben von Art. 2 ZGB ist somit eine (zu konkretisierende) **Grundschutznorm**²⁰⁹ im Sinne einer **Verhaltensnorm**,²¹⁰ deren Verletzung Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR bedeutet.²¹¹

Mit der höchstrichterlich geschaffenen Vertrauenshaftung (vgl. hinten N 108 ff.) hat das BGer auf die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit verzichtet und einen neuen Haftungstyp geschaffen, der weder deliktischer noch vertraglicher Natur ist.²¹² Ob das BGer dadurch gegen die dem schweizerischen Schuldrecht zugrunde liegende Dichotomie zwischen deliktischer und vertraglicher Haftung verstösst,²¹³ mag dahingestellt bleiben, denn die Frage wird obsolet, wenn Art. 2 ZGB im vorstehend dargelegten Sinn als Grundschutznorm anerkannt wird.²¹⁴ Auf dem gleichen Weg liesse sich auch die Haftung aus c.i.c. ins Recht der unerlaubten Handlung integrieren, ohne auf eine vorbestehende Sonderverbindung abstellen zu müssen.

4. Widerrechtlichkeit durch Unterlassung (Verletzung einer Garantenstellung) im Besonderen

4.1 Grundsatz der befugten Untätigkeit

Eine allgemeine Rechtspflicht, im Interesse anderer tätig zu werden, besteht nicht. Es ist vom «Grundsatz der befugten Untätigkeit» auszugehen.²¹⁵ Eine Unterlassung ist nur dann rechtswidrig, wenn ein Tun im Interesse des Geschädigten vorgeschrieben ist.²¹⁶ «Eine allgemeine Rechtspflicht, im Interesse anderer tätig zu werden, besteht nicht. [...] vielmehr ist die Handlungspflicht nur dann

haftpflichtrechtlich von Bedeutung, wenn sie im Interesse des Geschädigten besteht und aus einer Schutzvorschrift zu dessen Gunsten folgt. Widerrechtliche Unterlassung setzt damit eine **Garantenstellung** für den Geschädigten voraus [...]».²¹⁷

[Seite 113] 4.2 Ausnahme: konkrete Handlungspflichten

Solche konkreten Handlungspflichten können sich nicht nur aus positiven Verhaltensnormen der ganzen Rechtsordnung ergeben, sondern auch aus dem ungeschriebenen Recht.²¹⁸ Bei nach herrschender Terminologie sog. «reinen Vermögensschäden» (vgl. N 54 und 63) haben diese Normen auch die Funktion der Widerrechtlichkeitsbegründung als sog. «Schutznormen».²¹⁹ Eine Handlungspflicht ist haftpflichtrechtlich somit nur dann bedeutsam, wenn sie im Interesse eines Geschädigten besteht.²²⁰ Eine widerrechtliche Unterlassung ist somit nur möglich, wenn eine **Garantenstellung** zugunsten des Geschädigten besteht. **104**

Solche Garantenstellungen können sich ergeben aus dem allgemein anerkannten, aber ungeschriebenen **Gefahrensatz**, der besagt, dass wer einen gefährlichen Zustand schafft, die notwendigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen hat,²²¹ wobei nur mit einer durchschnittlichen Vorsicht und Vernunft der Umwelt gerechnet werden darf. **105**

Die dogmatische Einordnung des Gefahrensatzes ist sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Lehre umstritten: **106**

- Entweder dient er zur Begründung der Widerrechtlichkeit²²²
- oder er wird im Rahmen des Verschuldens verwendet.²²³

Mit der in der neueren Lehre vertretenen Auffassung, der sich das BGer angeschlossen hat,²²⁴ ist der Gefahrensatz zur Begründung der Widerrechtlichkeit einer Unterlassung nicht geeignet. Der Gefahrensatz ist eine **Frage des Verschuldens**,²²⁵ denn er gehört nicht zu den Grundschutznormen (vgl. vorne N 87), «von denen jede ein bestimmtes Rechtsgut in umfassender Weise gegen jede Art von Verletzung schützt» (vgl. auch vorne N 87 f.).²²⁶ Schafft ein Schädiger einen gefährlichen Zustand, ohne die erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen, so ist dies bei der objektiven Seite des Verschuldens (vgl. hierzu hinten N 163 ff.) zu berücksichtigen.²²⁷

HEIERLI/SCHNYDER wollen bei Unterlassungen «das Bestehen einer (objektiven) Garantenstellung bzw. das Vorhandenseins einer Verkehrssicherungspflicht schon bei der Widerrechtlichkeit» prüfen. Denn wenn in einem Schadensfall niemandem der Vorwurf einer **[Seite 114]** rechtswidrigen Unterlassung gemacht werden könne, weshalb ein Geschädigter den Schaden selbst zu tragen habe (bei Verletzung eines absoluten Rechts), so diene der Gefahrensatz dazu, «den normativen Zusammenhang zwischen Unterlassung und Erfolg herzustellen».²²⁸ **107**

5. Vertrauenshaftung

In freier richterlicher Rechtsfortbildung und mit Blick auf die deutsche Lehre zum BGB entwickelte das BGer als neuen Haftungstyp die sog. «**Vertrauenshaftung**».²²⁹ Sie gilt als **eigenständige dritte Haftungsgrundlage** zwischen Delikt und Vertrag.²³⁰ **108**

Als Oberbegriff soll sie die Haftung aus c.i.c «und interessenmässig gleich gelagerte Tatbestandsgruppen wie etwa die Haftung für falsche Auskunft bzw. Berufspflichten zum Schutze fremden Vermögens» umfassen.²³¹ **109**

Die dogmatische Grundlage der Vertrauenshaftung ist strittig; die Qualifikationen reichen von deliktischer,²³² über quasi-vertraglicher bis zur sui generis-Haftung,²³³ ja sogar vertragsrechtliche Grundsätze werden herangezogen.^{234, 235} **110**

Mit der Vertrauenshaftung hat die Rechtsprechung einen neuen Haftungstyp kreiert, der auf die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit verzichtet (vgl. **111**

bereits vorne N 102). Für einen Anspruch aus Vertrauenshaftung sind nach h.M. kumulativ zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

- a. es muss eine rechtliche Sonderverbindung bestanden haben und
- b. ein dadurch erwecktes Vertrauen muss enttäuscht worden sein.²³⁶

So sehr die Vertrauenshaftung auch als gefestigte Rechtsfigur betrachtet werden mag²³⁷ und so sehr diese richterliche Rechtsfortbildung begrüsst wird, da diese Haftung die Funktion eines Auffangtatbestandes erfülle,²³⁸ so sehr zeigt das BGer selbst die Überflüssigkeit der [Seite 115] Vertrauenshaftung, wenn es aus demselben Sachverhalt kumulativ eine Haftung aus Delikt als auch eine Vertrauenshaftung ableitet.²³⁹ Im Weiteren lehnt das BGer selbst die andernorts für eine Vertrauenshaftung viel beschworene Sonderbeziehung im Entscheid BGE 130 III 345 (Liegenschaftenschätzer-Entscheid) ab, wodurch die Untauglichkeit der Theorie der rechtlichen Sonderbeziehung klar offenbart wird.²⁴⁰ 112

So wünschenswert eine gewisse Flexibilisierung unserer Rechtsordnung und Rechtsprechung auch sein mag, die Vertrauenshaftung ist nicht nur vage, öffnet der Willkür Tür und Tor,²⁴¹ sondern ist auch überflüssig angesichts der hier vorgeschlagenen Möglichkeit, sie (und die c.i.c.) stringent ins klassische Recht der unerlaubten Handlung einzuordnen durch Anerkennung des Prinzips von Treu und Glauben als Grundschutznorm mit entsprechender Unternormbildung, bei deren Verstoß Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR gegeben ist (vgl. vorne N 92 ff., insb. N 97–102).²⁴² 113

6. Ausschluss der Widerrechtlichkeit durch Rechtfertigungsgründe

6.1 Allgemeines

Die Rechtsordnung anerkennt verschiedene Rechtfertigungsgründe, welche die an sich gegebenen Widerrechtlichkeit eines Eingriffs ausschliessen.²⁴³ Daneben gibt es auch Rechtfertigungsgründe, die zwar nicht zum Ausschluss der Widerrechtlichkeit, aber zur Reduktion des Schadenersatzes führen können.²⁴⁴ 114

6.2 Überblick über die Rechtfertigungsgründe

Die Rechtfertigungsgründe sind überblicksmässig wie folgt zu systematisieren:²⁴⁵ 115

(1) Rechtmässige Ausübung öffentlicher Gewalt (**Amtshandlung**) (vgl. N 116 f.);

(2) **Subjektive Privatrechte** wie:

- Art. 57 OR: Retention eines Tieres (vgl. die entsprechende Kommentierung),
- Art. 268 OR: Retentionsrecht des Vermieters,
- Art. 434 OR: Retentionsrecht des Kommissionärs,
- Art. 491 OR: Retentionsrecht des Gastwirts,
- Art. 271 SchKG: Retentionsrecht des Gläubigers im Arrestfall,
- [Seite 116] – Art. 268b OR: Beizug polizeilicher Hilfe zur Rückschaffung von Retentionsgegenständen,
- Art. 745 ZGB: Genuss der Sache durch den Nutzniesser,
- Art. 302 Abs. 1 ZGB: Erziehungsrecht der Eltern (ohne Züchtigungsrecht);

(3) **Einwilligung des Geschädigten** (vgl. N 119 ff.);

(4) **Private Rechtfertigungsgründe** (vgl. die entsprechende Kommentierung):

- Art. 52 Abs. 1 OR: Notwehr,
- Art. 52 Abs. 2 OR: Notstand,
- Art. 53 Abs. 3 OR: (erlaubte) Selbsthilfe.

6.3 Einzelne Rechtfertigungsgründe

a) Ausübung öffentlicher Gewalt (Amtshandlungen)

Oft greifen Amtshandlungen in geschützte Rechtsgüter ein und bewirken Schäden.²⁴⁶ Die rechtmässige Amtshandlung rechtfertigt den Eingriff, wenn dieser zwangsläufig mit der Durchführung des Gesetzes verbunden ist.²⁴⁷ Unbeabsichtigte und unnötige Nebenfolgen einer rechtmässigen Tätigkeit sind nicht gerechtfertigt.²⁴⁸ 116

Voraussetzung einer rechtmässigen Amtshandlung ist auch, dass sie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahrt und in pflichtgemässen Ermessen gehandelt wurde.²⁴⁹ 117

b) Subjektive Privatrechte

Nimmt ein Schädiger kraft eines subjektiven Privatrechts die schädigende Handlung vor, ist die an sich gegebene Widerrechtlichkeit ausgeschlossen (vgl. die Aufstellung vorn N 115). 118

c) Einwilligung des Geschädigten

Willigte der Geschädigte in die schädigende Rechtsgutverletzung ein, so wird der Eingriff dadurch grundsätzlich rechtmässig: **Volenti non fit injuria**.²⁵⁰ Voraussetzung ist allerdings, dass die Einwilligung ihrerseits nicht unzulässig, d.h. weder widerrechtlich noch unsittlich ist, was Nichtigkeit nach Art. 20 Abs. 1 OR zur Folge hätte. 119

Art. 44 Abs. 1 OR sieht die Einwilligung des Geschädigten nur als Herabsetzungsgrund vor. Lehre und Rechtsprechung sind sich aber einig, dass eine gültige Einwilligung bereits die [Seite 117] Widerrechtlichkeit ausschliesst, eine mangelhafte Einwilligung ist im Rahmen von Art. 44 OR zu berücksichtigen.²⁵¹ 120

Als einseitiges Rechtsgeschäft²⁵² ist die Einwilligung grundsätzlich immer widerrufbar, allerdings dann nicht mehr, wenn der Eingriff, dem zugestimmt wurde, bereits ausgeführt ist oder wenn gültige Vertragsabreden entgegenstehen.²⁵³ 121

«Volenti non fit injuria» gilt nur, soweit der Geschädigte über das Rechtsgut, in dessen Verletzung er einwilligt, verfügen darf (bspw. ist die Einwilligung in die Tötung ungültig). Einwilligung setzt Handlungsfähigkeit voraus, ausser dort, wo über ein höchstpersönliches Recht verfügt wird, wo nach Art. 19c ZGB Urteilsfähigkeit genügt; sie bezieht sich nur auf Verletzungen, die der Einwillige bewusst gewollt hat (Absicht oder Eventualvorsatz), und sie muss im Voraus erklärt werden.²⁵⁴ Bei bloss rückwirkender, d.h. nachträglicher Einwilligung des Verletzten bleibt die Handlung rechtswidrig;²⁵⁵ die nachträgliche Einwilligung kann jedoch u.U. in einen Erlass der Schadenersatzforderung umgedeutet werden.²⁵⁶ 122

Einwilligungen in **ärztliche Behandlungen**, insbesondere Operationen, beziehen sich nur – aber immer auch – auf Risiken, die mit der ordentlichen Durchführung verbunden sind, nicht aber auf solche, die ihre Ursache in einem Behandlungsfehler haben.²⁵⁷ Die Einwilligung reicht nur so weit, als der Patient über die mit dem Eingriff verbundenen Risiken informiert wurde (ärztliche Aufklärungspflicht). Immerhin ist der Nachweis der hypothetischen Einwilligung 123

des Patienten, bezogen auf den konkreten Fall, zugelassen (vgl. auch die Kommentierung zu Art. 28/28a ZGB).²⁵⁸

Die Aufklärung über die Risiken des Eingriffs, die dokumentiert sein muss und an die sehr hohe Anforderungen gestellt werden,²⁵⁹ muss in verständlicher Sprache erfolgen und so umfassend wie möglich sein. Dazu gehören: Diagnose, Therapie, Prognose, alternative Behandlungsmöglichkeiten, Operationsrisiken, Heilungschancen, Hinweise auf spontane Krankheitsentwicklungen sowie Versicherungsfragen (Kostenübernahmen etc.).²⁶⁰ **124**

Erfolgte die Aufklärung nicht oder nur ungenügend, so ist einerseits die erteilte Einwilligung unwirksam (vgl. N 123), andererseits handelt der Arzt immer widerrechtlich und haftet für jeden aus seinem Eingriff resultierenden Schaden, unabhängig von einem Kunstfehler.²⁶¹ **125**

[Seite 118] Von der Verletzung der Aufklärungspflicht und dem daraus resultierenden Vermögensschaden (vgl. N 125) ist der sog. «**Aufklärungsschaden**» zu unterscheiden. Dieser besteht bspw. in einer Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes (z.B. schädliche Angstzustände) und entsteht bei empfindlichen Patienten durch eine zu umfassende Aufklärung (z.B. deprimierende Prognose).²⁶² **126**

Das **akzeptierte bzw. erlaubte Risiko** bzw. **das Handeln auf eigene Gefahr** ist eine besondere Form der Einwilligung.²⁶³ Soweit z.B. Kampfsport und andere Sportarten erlaubt sind und die Spielregeln eingehalten werden, liegt ggf. eine Schädigung in erlaubter Weise vor. Immerhin ist mit spielbedingten Verletzungen der Regeln zu rechnen.²⁶⁴ **127**

d) Wahrung höherer Interessen

Ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist indessen über den Bereich der traditionellen Rechtfertigungsgründe hinaus immer nur dann als rechtmässig zu betrachten, wenn er «in angemessener Wahrung höherer Interessen erfolgt. Der Entscheid über die Widerrechtlichkeit hängt somit weitgehend von einer Abwägung der einander gegenüberstehenden Güter oder Interessen ab [...]».²⁶⁵ **128**

e) Private Rechtfertigungsgründe

Zu den sog. «privaten Rechtfertigungsgründen» Notstand, Notwehr und (erlaubte) Selbsthilfe vgl. die Kommentierung zu **Art. 52 OR**. **129**

D. Kausalzusammenhang

1. Allgemeines

Unter Kausalzusammenhang versteht man ganz allgemein die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung.²⁶⁶ Für das Haftpflichtrecht geht es spezifisch um die Beziehung zwischen Schadensursache (Verhalten der in Anspruch genommenen Person) und Schaden. Dieser ursächliche Zusammenhang ist eine weitere Haftungsvoraussetzung (vgl. vorne N 14). Dabei muss sich das Verhalten der in Anspruch genommenen Person (Schadensursache) so ausgewirkt haben, dass es naturgesetzlich betrachtet die Ursache des Schadens ist (sog. «natürliche Kausalität», vgl. N 131 ff.). Andererseits aber muss der Zusammenhang auch adäquat (= angemessen) sein, damit er rechtlich erheblich ist (sog. «adäquate Kausalität», vgl. N 135 ff.). Der Kausalzusammenhang i.S. der Zurechenbarkeit ist Haftungsvoraussetzung, ermöglicht aber auch, von der Schadensursache auf den dafür Haftpflichtigen zu schliessen.²⁶⁷ **130**

[Seite 119] zung, ermöglicht aber auch, von der Schadensursache auf den dafür Haftpflichtigen zu schliessen.²⁶⁷

2. Natürlicher Kausalzusammenhang

Der natürliche Kausalzusammenhang ist nach logischen und naturgesetzlichen Gesichtspunkten zu bewerten.²⁶⁸ Danach ist ein Ereignis im natürlichen Sinne kausal, wenn es nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiel; dieses (Ereignis) braucht nicht alleinige oder unmittelbare Ursache des Erfolgs zu sein. Mit anderen Worten «besteht ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen zwei Ereignissen, wenn das zweite Ereignis ohne das erste nicht eingetreten wäre» (**conditio sine qua non**).²⁶⁹ 131

Mit dieser Bedingungsformel wird hypothetisch untersucht und geprüft, was beim Weglassen bestimmter Tatsachen geschehen wäre. Die Fragestellung lautet somit: Wäre der Schaden auch eingetreten, wenn das betreffende Ereignis nicht stattgefunden hätte, stellt also das betreffende Ereignis eine notwendige Bedingung für den Schaden dar? Ein solchermassen vermuteter natürlicher Kausalverlauf lässt sich nicht mit Gewissheit beweisen, weshalb es genügt, wenn das Ereignis mindestens mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildet.²⁷⁰ Es bedarf einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit, eine blosser Möglichkeit der Verursachung reicht nicht (sog. «Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit»).²⁷¹ Kausalität ist dann nicht gegeben, wenn der Schaden auch ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre.²⁷² 132

Die Feststellung des natürlichen Kausalzusammenhangs ist Tatfrage und deshalb vom BGer nicht überprüfbar, Willkür vorbehalten.²⁷³ 133

Natürlich kausale Ursachen können in einem Tun oder in einer Unterlassung bestehen.²⁷⁴ Mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist oft die Prüfung des Kausalzusammenhangs bei Unterlassungen, «weil hypothetisch darüber zu befinden ist, ob ein Geschädigter bei Nichtvorhandensein der Unterlassung sich anders verhalten hätte». ²⁷⁵ Der natürliche Kausalzusammenhang beruht bei einer Unterlassung auf der hypothetischen Annahme, bei [Seite 120] rechtmässigem Handeln wäre der Schaden nicht eingetreten.²⁷⁶ Bei der Prüfung dieser Fragen, in der normalerweise auf die allgemeine Lebenserfahrung abgestellt wird, wodurch unwahrscheinliche Geschehensabläufe unbeachtlich bleiben, kommen bereits bei der hypothetischen (natürlichen) Kausalität wertende Gesichtspunkte ins Spiel, die eigentlich erst bei der Beurteilung der Adäquanz bedeutsam sind.²⁷⁷ Eine zusätzliche Prüfung der Adäquanz wird dadurch obsolet.²⁷⁸ «Die Beachtung der konkreten Umstände und deren Würdigung führen somit zu einer **Vorverlagerung der Adäquanzfrage**». ²⁷⁹ Trotzdem handelt es sich hier immer noch um eine Tatfrage mit der entsprechenden Bindungswirkung für das BGer.²⁸⁰ 134

3. Adäquater Kausalzusammenhang

3.1 Begriff

Rein naturgesetzlich betrachtet können sich Kausalketten unendlich fortsetzen. Bei blosser Berücksichtigung der tatsächlichen Verursachung ginge eine Haftung ins Uferlose. Da eine solche Zurechnung dem Haftpflichtigen nicht zugemutet werden darf, geht es darum, die Haftung auf jene Ursachen zu beschränken, die dem Schädiger vernünftigerweise noch zugemutet werden können, d.h. angemessen (= adäquat) sind. Bei der Berücksichtigung der Adäquanz geht es somit um eine **Begrenzung der Haftung**.²⁸¹ 135

Adäquanz liegt vor und eine Ursache ist dann haftungsbegründend, wenn sie «nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens geeignet» ist, «einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen». ²⁸² «Unter Berücksichtigung aller Umstände, aber auch des Zwecks der einschlägigen Haftungsnorm ist danach zu fragen, ob der Eintritt des Schadens bei wertender Betrachtung billigerweise noch dem Haftpflichtigen zugerechnet 136

werden darf [...]»²⁸³ Die Adäquanz ist **somit ein normatives Korrektiv** zum naturwissenschaftlichen Ursachenbegriff und ein **Werturteil** bezüglich der Zurechnung eines Schadens an einen Schädiger.²⁸⁴ Dabei ist einzig die **objektive Voraussehbarkeit** des Schadensereignisses entscheidend.²⁸⁵ Folge dieser Normativierung und Objektivierung ist, «dass der adäquate Kausalzusammenhang auf dem Weg der *nach [Seite 121] träglichen (oder retrospektiven) Prognose* zu beurteilen ist»,²⁸⁶ wobei alle «ex post bekannten Umstände» berücksichtigt werden müssen.²⁸⁷ Selbst aussergewöhnliche Folgen können u.U. dabei adäquat sein.²⁸⁸

Die Adäquanz ist eine Rechtsfrage und unterliegt der bundesgerichtlichen Kognition.²⁸⁹ Die Beweislastregeln von **Art. 8 ZGB** kommen folglich nicht zur Anwendung; «als Rechtsfrage ist die Adäquanz keinem Beweis zugänglich».²⁹⁰ **137**

3.2 Adäquanz bei Unterlassung

Auch durch Unterlassung kann der adäquate Kausalzusammenhang begründet werden.²⁹¹ Bei der Adäquanz einer Unterlassung wird geprüft, ob die erwartete (aber unterlassene) Handlung nicht hinzugedacht werden könne, ohne dass der Erfolg höchstwahrscheinlich entfielen.²⁹² «Rechtlich wird dabei dem Haftpflichtigen der Vorwurf gemacht, er unterlasse die Änderung des Kausalablaufs, zu der er verpflichtet wäre.»²⁹³ Hätte rechtzeitiges Handeln den Eintritt des Schadens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit verhindert, so wird der sog. «**hypothetische Kausalzusammenhang**» bejaht.²⁹⁴ **138**

Zur unterschiedlichen Anwendung des Adäquanzbegriffs im **Sozialversicherungsrecht** vgl. BGer **4A_45/2009**, E. 3.3.2; **BGE 123 V 98**, E. 3.d; zur **subjektiven Voraussehbarkeit** vgl. N 159 bei Verschulden. **139**

3.3 Fehlende Adäquanz

a) An sich inadäquater Kausalzusammenhang

Beim an sich inadäquaten Kausalzusammenhang fehlt es von vornherein an der Adäquanz. Ein natürlicher Kausalzusammenhang ist zwar zwischen Ursache und Erfolg gegeben, doch nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung ist die fragliche Ursache nicht generell geeignet, den eingetretenen Schaden zu bewirken.²⁹⁵ **140**

[Seite 122] b) Wegfall/Unterbrechung der Adäquanz

Nur der adäquat kausale Zusammenhang zwischen Ursache und Schaden ist haftungsbegründend. Adäquanz ist nicht mehr gegeben, d.h., sie wird unterbrochen, wenn der Erfolg nur durch das Hinzutreten ganz aussergewöhnlicher und ausserhalb des normalen Geschehens liegender Umstände möglich war. «Der adäquate Kausalzusammenhang wird unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen [...]»²⁹⁶ **141**

Als solche die Kausalität **unterbrechende Drittsachen** kommen in Frage: **höhere Gewalt** («unvorhersehbares und unvermeidliches Ereignis, das [...] mit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht»)²⁹⁷ oder ein Umstand, den ein **142**

Dritter zu vertreten hat (**grobes Drittverschulden**), bzw. ein Umstand, der beim Geschädigten selbst liegt (**grobes Selbstverschulden**).²⁹⁸

Im Rahmen der Verschuldenshaftung von Art. 41 Abs. 1 OR kann auch der Zufall die Adäquanz unterbrechen, sofern seine Rolle – z.B. im Vergleich mit dem geringen Verschulden des Schädigers – bedeutend genug ist.²⁹⁹ 143

Nicht jede Drittursache vermag den adäquaten Kausalzusammenhang zu unterbrechen. Solange die Drittursache nicht so sehr ausserhalb des normalen Geschehens liegt, dass damit schlechterdings nicht zu rechnen war, bleibt die adäquate Kausalität der ersten Ursache bestehen.³⁰⁰ 144

Unterbricht ein Selbstverschulden den Kausalzusammenhang nicht, ist i.d.R. die Schadenersatzforderung zu reduzieren. Gewöhnliches (nicht grobes) Drittverschulden hat keinen Einfluss auf den Anspruch des Geschädigten.³⁰¹ 145

Zur Kasuistik zur fehlenden Adäquanz vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 144 ff. 146

3.4 Besondere Kausalitätsformen

Mehrere Ursachen können rechtlich erheblich zu einem Schaden beitragen, und zwar derart, dass jede für sich allein den bewirkten Schaden hätte herbeiführen können (**kumulative Kausalität**), oder so, dass nur durch das Zusammenwirken mehrerer Ursachen der Schaden [Seite 123] entstehen konnte (**Teil- oder Mitursache**). In beiden Fällen haftet jeder Schädiger für den gesamten Schaden.³⁰² 147

Zufall (vgl. Art. 43 OR N 13) oder **Mitwirkung des Geschädigten** sind im Rahmen der Schadenersatzbemessung (Art. 43/44 OR) zu berücksichtigen. Bei **konstitutioneller Prädisposition** des Geschädigten als Teilursache wird z.B. unterschieden zwischen Vorzuständen, die sich auch ohne das schädigende Ereignis ausgewirkt hätten (sie sind im Rahmen der Schadensberechnung zu berücksichtigen, vgl. dazu die Kommentierung zu Art. 42 OR N 27), und solchen, die den Schaden begünstigen resp. vergrössern (auch diese sind im Rahmen von Art. 43/44 OR zu berücksichtigen [vgl. u.a. die Kommentierung zu Art. 44 OR N 19 ff.]).³⁰³ 148

Die adäquate Kausalität gilt als nicht erwiesen, wenn nur die eine oder die andere Ursache für einen Schaden kausal gewesen sein kann (**alternative Kausalität**). Alternative Kausalität stellt nicht ein Kausalitäts-, sondern vielmehr ein Beweisproblem dar, mit der Konsequenz, dass kein Schädiger haftet, «solange nicht bewiesen werden kann, wer tatsächlich den Schaden verursacht hat».³⁰⁴ 149

Ist der Schaden bereits eingetreten, bevor jemand noch eine zweite Ursache setzt (**überholende Kausalität**), fehlt es für die zweite Ursache an der natürlichen Kausalität (Überfahren eines bereits toten Verkehrsopfers), weshalb der Urheber der zweiten Ursache nicht haftet.³⁰⁵ 150

E. Verschulden

1. Verschulden als Haftungszurechnungsgrund

Vgl. zur Bedeutung des Verschuldens als Haftungszurechnungsgrund Vor Art. 41–61 OR N 17 ff., insb. N 19. 151

2. Begriff und Funktion

Verschulden i.S.d. Zivilrechts ist ein menschliches Verhalten, das die Ursache eines Schadens darstellt und als so tadelnswert angesehen wird, dass es die Haftbarmachung des Schädigers zu rechtfertigen vermag.³⁰⁶ Dieses Verhalten muss dem Handelnden persönlich vorwerfbar sein.³⁰⁷ 152

Im Verschuldensvorwurf «liegt eine negative, missbilligende rechtliche Qualifikation menschlichen Verhaltens»,³⁰⁸ weil es gegen eine von der 153

Rechtsordnung statuierte Pflicht verstösst.³⁰⁹

Im Zivilrecht herrscht ein anderer Begriff als im Strafrecht. Zur Nichtbindung des Zivilrichters an die strafrechtliche Beurteilung der Verschuldensfrage vgl. Kommentierung zu **Art. 53 OR**. **154**

Neben der Funktion des Verschuldens als Haftungszurechnungsgrund (vgl. vorne N 151) hat es auch seine Bedeutung als Massstab für die Schadenersatzbemessung (Art. 43/44 OR). **155**

Auch eine kausalhaftpflichtige Person kann ein sog. «**zusätzliches Verschulden**» treffen. Bedeutsam wird dieses, wenn ein Selbstverschulden des Geschädigten vorliegt, das einen Reduktionsgrund darstellt. Nach h.M. führt ein zusätzliches Verschulden zur Neutralisation des Reduktionsgrundes, so dass der Kausalhaftpflichtige doch den ganzen Schaden zu ersetzen hat.³¹⁰ **156**

3. Verschuldenskomponenten

3.1 Überblick

Das Verschulden weist eine objektive und eine subjektive Komponente auf: **157**

- Die **subjektive Komponente** besteht in der Urteilsfähigkeit,
- die **objektive** in der Abweichung vom gesetzlich geforderten durchschnittlich schädigungsvermeidenden Verhalten.³¹¹

Grundsätzlich ist die Erfüllung beider Verschuldenskomponenten Haftungsvoraussetzung. Fehlt die Urteilsfähigkeit (subjektive Komponente), kommt es allenfalls zur Billigkeitshaftung urteilsunfähiger Personen nach **Art. 54 OR** (vgl. die entsprechende Kommentierung). **158**

[Seite 125] 3.2 Urteilsfähigkeit als subjektive Verschuldenskomponente

Als Haftungsgrundlage setzt das Verschulden Urteilsfähigkeit des Schädigers voraus. Handlungsfähigkeit ist nicht erforderlich (**Art. 19 Abs. 3 ZGB**). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (**Art. 16 ZGB**). Zur Urteilsfähigkeit gehören die Fähigkeit, die Folgen (Gefahren) einer Handlung zu erkennen, die Einsicht in die Schädigungsmöglichkeit (intellektuelle Komponente)³¹² sowie der Wille und die Kraft, sich entsprechend zu verhalten (charakterliche Komponente: Willenskraft zur Unterlassung).³¹³ **159**

Im Gegensatz zur objektiven Verschuldenskomponente gibt es nach überwiegender Lehre keine Abstufungen der Urteilsfähigkeit; sie ist entweder für eine bestimmte Handlung gegeben oder nicht.³¹⁴ Insofern ist sie jedoch ein **relativer Begriff**, als sie von Fall zu Fall und unter Berücksichtigung aller Umstände zu beurteilen ist.³¹⁵ Nach Ansicht des BGer und einem Teil der Lehre ist eine Abstufung der Urteilsfähigkeit jedoch möglich.³¹⁶ **160**

Nicht vorausgesetzt ist, dass der Schädiger die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens erkennen kann.³¹⁷ Die Urteilsfähigkeit muss im Zeitpunkt der Handlung/Unterlassung gegeben sein, und zwar gerade im Hinblick auf das in Frage stehende Verhalten.³¹⁸ Insbesondere bei Kindern wird konkret auf deren Entwicklungsstand und die Anforderung, welche die betreffende Lage an vernunftgemässes Handeln stellt, abgestellt.³¹⁹ Verminderte Urteilsfähigkeit ist im Rahmen der Schadenersatzbemessung (**Art. 43 OR**) zu berücksichtigen. **161**

Gemäss **Art. 16 ZGB** wird das Vorliegen der Urteilsfähigkeit vermutet.³²⁰ Urteilsunfähigkeit muss derjenige beweisen, der sie behauptet.³²¹ **162**

3.3 Vorsatz oder Fahrlässigkeit als objektive Verschuldenskomponente

a) Vorsatz (Absicht)

Vorsatz (oder Absicht) liegt vor, wenn der Täter sowohl die Handlung als auch deren Erfolg bewusst und gewollt herbeiführt. Mit **Eventualvorsatz** handelt, wer den Erfolg zwar nicht will, mindestens aber mit der Möglichkeit des Erfolges rechnet und diesen, für den Fall, [Seite 126] dass er eintreten sollte, auch in Kauf nimmt,³²² d.h., sich gleich verhalten würde, wenn er wüsste, dass der Schaden sicher eintritt (in Abgrenzung zur groben Fahrlässigkeit, wo der Schädiger sich des Risikos einer Schadensverursachung bewusst ist, jedoch darauf vertraut, dass der mögliche Erfolg nicht eintritt).³²³ **163**

Normalerweise wird zwischen Absicht, Vorsatz und Eventualvorsatz *nicht* unterschieden.³²⁴ Wesentlich für das Haftpflichtrecht und damit für die Haftungsbegründung ist, dass der Schädiger «um die Schädlichkeit seines Eingriffs wusste und den schädigenden Eingriff will [...] oder in Kauf nimmt».³²⁵ Die Differenzierung kann jedoch für die Bemessung des Schadenersatzes bedeutsam sein (vgl. die Kommentierung zu **Art. 43 Abs. 1 OR**). **164**

b) Fahrlässigkeit

aa) Allgemeines

Fahrlässigkeit ist rechtlich «missbilligte Unsorgfalt».³²⁶ «Vorwerfbar ist bei der Fahrlässigkeit ein jeweils objektiv zu messender Mangel an Sorgfalt.»³²⁷ Dies bedeutet Ausserachtlassung derjenigen Sorgfalt, welche die Verkehrssitte von den mit dem Handelnden in gleichen erkennbaren Lebensverhältnissen stehenden Personen unter den erkennbaren konkreten Umständen fordert. Fahrlässig handelt somit, wer die vorhersehbare Schädigung eines Dritten nicht beachtet,³²⁸ die Sorgfalt vermissen lässt, zu der er nach dem Umständen (Ort, Zeit, sonstige Gegebenheiten: Alter, Beruf des Schädigers) verpflichtet ist. **165**

Im Haftpflichtrecht gilt ein **objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff**.³²⁹ Nur objektive Umstände fallen in Betracht; subjektive Umstände wie seelische Belastung, grosse Trauer u.ä. werden im Zivilrecht nicht berücksichtigt. «Der Mangel an Sorgfalt wird festgestellt durch den Vergleich des tatsächlichen Verhaltens des Schädigers mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers. Jede negative Abweichung von diesem geforderten Durchschnittsverhalten gilt als sorgfaltswidrig und damit als fahrlässig.»³³⁰ **166**

Wer durch einen Dritten plötzlich in eine gefährliche Lage versetzt wird und von verschiedenen möglichen Massnahmen nicht diejenige ergreift, welche bei nachträglicher Überlegung als die objektiv zweckmässigste erscheint (Fehlreaktion), handelt dann nicht fahrlässig, wenn die ergriffene Massnahme der «richtigen» annähernd gleichwertig ist und die unterschiedliche Wirksamkeit nur wegen des Erfordernisses des raschen Handelns nicht erkannt werden konnte.³³¹ Da «alle erforderliche» Sorgfalt verlangt wird und nicht nur die übliche, kann sich auch die Übung langjähriger Bräuche als Sorgfaltspflichtverletzung erweisen.³³² **167**

bb) Arten der Fahrlässigkeit

Da Fahrlässigkeit ein Abweichen vom durchschnittlich schadenvermeidenden Verhalten darstellt (vgl. vorne N 165 f.), sind grundsätzlich beliebig viele Abweichungen und damit verschiedene Grade der Fahrlässigkeit denkbar. Diese Abstufungen erlauben es bei der Schadenersatzbemessung dem Verschulden gebührend Rechnung zu tragen.³³³ **168**

In wenigen Fällen stellt das OR auf eine Zweiteilung in «grobe Fahrlässigkeit» und «leichte Fahrlässigkeit» ab, nämlich in: Art. 100 Abs. 1, Art. 248, **Art. 452** und **Art. 454** **169**

Abs. 3 OR (ebenso: **Art. 14 Abs. 2** und **Art. 72 Abs. 3 VVG**).³³⁴ Lehre und Praxis gebrauchen teilweise noch die Zwischenstufe «mittlere Fahrlässigkeit».³³⁵

Grobe Fahrlässigkeit ist immer schweres Verschulden und ist die **170**
Ausserachtlassung der elementarsten Vorsichtsgebote, d.h., wenn unberücksichtigt bleibt, was jedem vernünftigen Menschen in der gleichen Lage und unter den gleichen Bedingungen hätte einleuchten müssen.³³⁶ Populär ausgedrückt liegt grobe Fahrlässigkeit vor, wenn man sagen muss: «Wie hätt er au nu chönne!».³³⁷

Leichte Fahrlässigkeit ist nach herkömmlicher Auffassung jede Fahrlässigkeit, die **171**
nicht grob ist,³³⁸ der Handelnde aber trotzdem Sorgfaltspflichten missachtet, die «die Verkehrssitte von den mit dem Handelnden in gleichen Lebensverhältnissen stehenden Personen unter den gleichen erkennbaren konkreten Umständen fordert».³³⁹ Leichte Fahrlässigkeit ist gegeben, wenn man – populär ausgedrückt – sagen muss: «Er hett scho sölle!».³⁴⁰

Mittlere (gewöhnliche) Fahrlässigkeit. Diese Zwischenstufe ist im Gesetz nicht **172**
vorgesehen. Das BGER hat sie kreiert und ein Teil der Lehre hat sie übernommen.³⁴¹ Diese Fahrläs [Seite 128] sigkeitsart lässt sich wie die leichte Fahrlässigkeit nur negativ umschreiben und soll vorliegen, wenn das Verschulden nicht leicht ist, aber doch nicht einen solchen Schweregrad erreicht, dass die Anwendung von **Art. 44 Abs. 2 OR** ausgeschlossen würde.³⁴²

cc) Hilfsmittel zur Feststellung der Fahrlässigkeit

Gefahrensatz: Zum Gefahrensatz als Hilfsmittel zur Feststellung der Fahrlässigkeit **173**
vgl. vorne N 105 ff.

Weitere Hilfsmittel: Zu weiteren Hilfsmittel hinsichtlich der Klärung der **174**
Fahrlässigkeitsfrage wie: (a) Verletzung von Polizeivorschriften, (b) Missachtung behördlicher Genehmigungen und Bewilligungen, (c) nachträglich getroffene Schutzmassnahmen sowie (d) frühere Schadensereignisse vgl. REY, Rz 872–879.

4. Verschulden bei der Haftung einer juristischen Person

Bei der Haftung der juristischen Person ist das Verschulden der Organe zu prüfen. **175**
Fehlt dieses, ist auch die juristische Person nicht haftbar (**Art. 55 Abs. 2 ZGB**).

5. Substitution des Verschuldens

Zur Substitution der Haftungsvoraussetzung Verschulden bei sog. **176**
«Kausalhaftungen» vgl. Vor **Art. 41–61 OR** N 19 f. und 25.

III. Haftpflicht versus Schadenersatzpflicht

Sind die Voraussetzungen von **Art. 41 Abs. 1 OR** erfüllt, so ist der Schädiger haftbar **177**
und folglich schadenersatzpflichtig; fehlt eine der vier Voraussetzungen (Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang, Verschulden), entsteht keine Haftpflicht. Es gilt der Grundsatz: «casum sentit dominus» (vgl. Vor **Art. 41–61 OR** N 16).

Wird wegen Erfüllung der Haftungsvoraussetzungen eine Haftpflicht des **178**
Schädigers festgestellt, bedeutet dies allerdings nicht, dass stets voll für den verursachten Schaden eingestanden werden muss. **Haftung und Schadenersatzpflicht sind immer zu unterscheiden.** Denn neben **Art. 41 Abs. 1 OR**, der den Haftungsgrundsatz regelt, konkretisieren weitere Normen die Höhe des Schadenersatzes (u.U. auch Reduktion der Schadenersatzpflicht [vgl. die Kommentierungen zu Art. 43 und 44 OR]) bzw. sehen Haftungsabwälzungen auf weitere Ersatzpflichtige im Rahmen des Rückgriffs vor (vgl. die Kommentierungen zu Art. 50 und 51 OR).³⁴³

[Seite 129] IV. Absichtliche Schädigung wider die guten Sitten (Abs. 2)

Die Anspruchsvoraussetzungen für eine Haftung nach Art. 41 Abs. 2 OR sind z.T. die gleichen wie in Abs. 1. Dies betrifft insbesondere die Voraussetzungen des Vermögensschadens und der Kausalität.³⁴⁴ An die Stelle der Widerrechtlichkeitsvoraussetzung tritt aber der **Verstoss gegen die guten Sitten** und die Schädigung muss nicht nur verschuldet, sondern in der Verschuldensform der **Absicht** (vgl. N 180) erfolgen.

Sittenwidrigkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 2 OR bezeichnet ein **ethisch vorwerfbares Verhalten**. Im Unterschied zur Widerrechtlichkeit ist Sittenwidrigkeit nicht ein Verstoss gegen eine konkrete Norm, sondern es ist jeweils auf den Fall bezogen zu untersuchen, was als Verstoss gegen die guten Sitten anzusehen ist.³⁴⁵ Bspw. ist die Ausführung von Verträgen, denen kein Mangel i.S.v. Art. 18 ff. OR anhaftet, nicht sittenwidrig.³⁴⁶ Der Begriffsinhalt unterliegt somit dem gesellschaftlichen Wandel und wird von dem jeweils herrschenden Gerechtigkeitsempfinden bestimmt.³⁴⁷

Abs. 2 findet nur dort selbständige Anwendung, wo eine Widerrechtlichkeit nicht gegeben ist. Vor dem Hintergrund, dass ein Verstoss gegen die guten Sitten auch ein Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZGB und damit gegen eine Grundsatznorm bedeuten kann, was Widerrechtlichkeit bedeutet (vgl. vorne N 92 ff., insb. N 98–101), ist der Anwendungsbereich der Norm beträchtlich eingeschränkt.

Der **Grundsatz der schonenden Rechtsausübung** ist für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit zentral. «Sittenwidrig ist danach grundsätzlich ein Verhalten, für das *eigene Interessen* vollständig fehlen und das ausschliesslich auf die Schädigung eines anderen zielt.»³⁴⁸

Der Tatbestand von Abs. 2 verlangt **absichtliche Schadenszufügung**, worunter gewöhnlicher Vorsatz verstanden wird.³⁴⁹

Zur Kasuistik vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 245 ff. sowie CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 56.

Fussnoten:

- 1 KELLER/GABI/GABI, S. 4.
- 2 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1a; KELLER/GABI/GABI, S. 4; OFTINGER I, S. 15: «wenn immer ein widerrechtlich zugefügter Schaden auf Verschulden zurückgeht, tritt Haftung ein (OR 41)».
- 3 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1a.
- 4 BGE 115 II 237, E. 2.a; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1a; OFTINGER I, S. 479; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 32 f.; REY, Rz 45 und 1247 f.
- 5 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1a (mit Angabe von weiteren solchen Normen).
- 6 Wo das kantonale Recht in seinem Anwendungsbereich auf Art. 41 ff. OR verweist, gilt dieses als stellvertretendes kantonales Recht (BGE 100 II 120, E. 2.b).
- 7 BGE 120 II 58, E. 3.a; 113 II 246, E. 3; 112 II 138, E. 3.b; 99 II 315, E. 5; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 11; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 3; KELLER/GABI/GABI, S. 11; OFTINGER I, S. 484; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 43 ff.; REY, Rz 39.
- 8 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 12; KELLER A., Haftpflichtrecht I, S. 421; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 43; REY, Rz 43.
- 9 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 11; KELLER A., Haftpflichtrecht I, S. 421; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 43, Fn 53; REY, Rz 44; SCHWENZER, Rz 54.04; a.M. BGE 113 II 246, E. 8.
- 10 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 12; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Rz 2944; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 20 Rz 24; SCHWENZER, Rz 54.04.
- 11 OFTINGER I, S. 479; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 32 f.; REY, Rz 45.
- 12 SCHWENZER, Rz 54.04; gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 12.
- 13 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 21 Rz 54; REY, Rz 46.

- 14 Zur Kontroverse vgl. REY, Rz 1236 f.
- 15 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1a.
- 16 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 13.
- 17 Vgl. hierzu statt vieler REY, Rz 41 f.; SCHWENZER, Rz 5.04.
- 18 BGE 87 II 155, E. 3.a; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 12.
- 19 OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 59 ff.; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 12; SCHWENZER, Rz 5.05.
- 20 OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 61; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 12; SCHWENZER, Rz 5.05.
- 21 BGE 120 II 58, E. 3.a; 107 II 161, E. 8.a f.; BK-BREHM, Art. 41 OR N 230a; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2; OFTINGER/STARK I, § 13 Rz 60; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor 41–61 N 12; SCHWENZER, Rz 5.05; VON TUHR/ESCHER, S. 109.
- 22 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2.
- 23 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 12 m.w.V.
- 24 BK-BREHM, Art. 41 OR N 232a; SCHWENZER, Rz 24.14.
- 25 SCHWENZER, Rz 5.05.
- 26 BK-BREHM, Art. 41 OR N 232b.
- 27 SCHWENZER, Rz 88.42 ff. mit Darstellung der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten; ebenso BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2a.
- 28 BGE 132 III 122, E. 4.1 = Pra 95 (2006), Nr. 107; OFK-FISCHER, Art. 41 OR N 13; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 2c; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 5; KELLER/GABI/GABI, S. 10 i.V.m. 61; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 19 i.V.m. 6; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 2; SCHWENZER, Rz 50.01.
- 29 BK-BREHM, Art. 41 OR N 67a und 69; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 67; GAUCH, recht 1996, S. 225; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 3; OFTINGER I, S. 62; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 62; REY, Rz 150.
- 30 BGE 132 III 359, E. 4; 127 III 73, E. 4.a; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 26; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 6, Fn 6.
- 31 BK-BREHM, Art. 41 OR N 69.
- 32 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 70 m.V. auf Art. 45 und 46 OR, die solche Positionen aufführen.
- 33 Gemäss OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 8, kann auch eine freiwillige Vermögensverminderung Schaden sein. Sie weisen darauf hin, dass auch eine freiwillige Vermögenseinbusse Schaden sein können müsse, ansonsten Art. 31 Abs. 3 OR keine Schadenersatzpflicht vorsehen könne.
- 34 OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 5.
- 35 BGE 127 III 403, E. 4; ferner BGE 132 III 321, E. 2.2.1; 132 III 186, E. 8.1; 129 III 331, E. 2.1; 129 II 49, E. 4.3.2; BGer 4C.338/2004, E. 3.2 = Pra 95 (2006), Nr. 7; BK-BREHM, Art. 41 OR N 70; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 3; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 20; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 4.
- 36 BGE 132 III 321, E. 2.2.1; 120 II 296; 116 II 441, E. 3; 115 II 474, E. 3; BK-BREHM, Art. 41 OR N 69; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 71; GAUCH, recht 1996, S. 226; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 3; KELLER/GABI/GABI, S. 10; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 20; OFTINGER I, S. 53 ff.; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 9; REY, Rz 151 ff.; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 18; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 4; VON TUHR/PETER, S. 84.
- 37 OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 9, Fn 15; REY, Rz 169.
- 38 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 1324.
- 39 Als Beispiel ist die Zerstörung eines Bandes einer mehrbändigen seltenen Buchausgabe zu erwähnen. Der konkrete Verlust ist nicht nur der Vermögensschaden aus der Zerstörung des Einzelbandes, sondern die Werteinbusse der nun unvollständigen Buchausgabe.
- 40 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 71.
- 41 REY, Rz 155.
- 42 BK-WEBER, Art. 97 OR N 148.

- 43 Vgl. hierzu die Kommentierung zu **Art. 42 OR** N 39 mit entsprechender Quellenangabe. – Positive Ausnahme ist einzig die Ersatzfähigkeit des Affektionswertes bei Verletzung oder Tötung eines Tieres im Rahmen von **Art. 43 OR** (vgl. die entsprechende Kommentierung).
- 44 **BGE 132 III 321**, E. 2.2.1.
- 45 **BGE 127 III 403**.
- 46 **BGE 132 III 359**, E. 3 ff. (unerwünschtes Kind als Schaden).
- 47 **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 3a**; REY, Rz 159 f.; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 24 f.; SCHWENZER, Rz 14.04. – **A.M. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 35**. – Vgl. zum Ganzen in grundsätzlicher Hinsicht HONSELL, Kind, S. 275 ff.; MÜLLER C., recht 2013, S. 46 ff. mit Darstellung aller möglichen Schadenskonstellationen: Wrongful-life-Klage = Schadenersatz/Genugtuungsklage des behindert geborenen Kindes; wrongful-birth-Klage = Schadenersatz/Genugtuungsklage der Eltern des behinderten Kindes; wrongful-conception; wrongful-pregnancy.
- 48 BGer **4A_282/2009**, E. 3; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 4**.
- 49 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 34.
- 50 **BGE 133 III 462 = Pra 97 (2008), Nr. 27**. Ablehnend sind auch: **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 6a**; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 43; REY, Rz 158a; differenzierend, da mit dieser Theorie das «Alles-oder-Nichts-Prinzip» zugunsten einer anteilmässigen Ersatzpflicht «aufgeweicht» werden könnte: BK-BREHM, **Art. 42 OR** N 56a; GAUCH, recht 1996, S. 228 mit Aufzählung der Anwendungsmöglichkeiten; CHK-MÜLLER, **Art. 42 OR** N 15 m.w.V.
- 51 KELLER/GABI/GABI, S. 13; SCHWENZER, Rz 14.05.
- 52 REY, Rz 176; SCHWENZER, Rz 14.05. – Mit bemerkenswerten Argumenten begegnet HANDSCHIN, S. 697 ff., insb. 712, den nachfolgend dargestellten Versuchen, die Differenztheorie zur Begründung eines fehlenden Schadens mit wertenden Kriterien (normativ) zu korrigieren. Nach ihm genügt die herrschende Differenztheorie, sofern man diese «getreu der Formel ›Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven‹ mit einem modernen Vermögensbegriff verbindet, wie er sich aus True and Fair-Rechnungslegungsvorschriften ergibt».
- 53 KELLER/GABI/GABI, S. 13.
- 54 **BGE 132 III 321**, E. 3.1.
- 55 BGer **4C.276/2001**, E. 6 = **Pra 91 (2002), Nr. 212**; **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 8**; SCHWENZER, Rz 14.10.
- 56 **BGE 129 III 331**, E. 2.2.
- 57 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 99 und 101.
- 58 BK-BREHM, **Art. 42 OR** N 20c.
- 59 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 99 ff., insb. 115.
- 60 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 116.
- 61 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 121 ff., insb. 125.
- 62 REY, Rz 372; **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 8**, spricht «von Erscheinungsformen des normativen Schadensbegriffs»; ebenso KELLER/GABI/GABI, S. 19 («weitere Kategorien von normativen Schäden»).
- 63 REY, Rz 373.
- 64 REY, Rz 374 (Hervorhebung durch Verfasser).
- 65 CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 8; **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 23**.
- 66 **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 4**; REY, Rz 374 ff.
- 67 REY, Rz 376.
- 68 BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 83; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 4**; REY, Rz 371 ff. – Zu den aus einem Nutzungsausfall konkret anfallenden Kosten vgl. vorne N 24 sowie **Art. 42 OR** N 37.

- 69 BGE 132 III 379, E. 3.3.2; 126 III 388, E. 11.a; 115 II 474, E. 3. – GL.M.: FELLMANN/KOTTMANN, Rz 85 und 88; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 4; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 Rz 54; KELLER/GABI/GABI, S. 19; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 23; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 70; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 8; vgl. auch SCHWENZER, Rz 14.09 m.w.H.
- 70 REY, Rz 184 ff.
- 71 REY, Rz 383–386.
- 72 SCHWENZER, Rz 14.08; vorsichtige Zustimmung durch GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Rz 2859; ebenso wohl auch GAUCH, recht 1996, S. 226 («Nach Massgabe der wirtschaftlichen Realien besteht jedenfalls kein Grund, den Kommerzialisierungs- oder Frustrationsgedanken von vornherein abzulehnen»).
- 73 SCHWENZER, Rz 14.07.
- 74 REY, Rz 389; ebenso FELLMANN/KOTTMANN, Rz 88; GAUCH, recht 1996, S. 226; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Rz 2860 ff.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 Rz 56; KELLER/GABI/GABI, S. 19; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 22; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 71 f.; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 8; SCHWENZER, Rz 14.07.
- 75 So grundlegend BGE 115 II 474, E. 3; ebenso BGE 127 III 403, E. 4; 126 III 388, E. 11.a; BK-BREHM, Art. 41 OR N 84c; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 4; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 22; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 56 ff.; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 8.
- 76 So schon im Jahre 1984 FISCHER, S. 276 ff. (bezüglich Art. 195 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 208 Abs. 2 OR). GL.M. 1986 GAUCH, ZSR 1986, S. 569, Fn 23 (für den die Schadenersatzansprüche nach Art. 8 Abs. 2 und Art. 109 Abs. 2 OR im Rahmen des negativen Vertragsinteresses auf der Frustrationslehre basieren) sowie im Jahre 1996 GAUCH, recht 1996, S. 226, betr. Art. 26 Abs. 1, Art. 404 Abs. 2 und Art. 475 Abs. 2 OR.
- 77 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 Rz 57.
- 78 LANGE/SCHIEHMANN, S. 256.
- 79 Vgl. grundlegend hierzu REY, Rz 179 ff.
- 80 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 88; zustimmend: BK-BREHM, Art. 41 OR N 84c; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 8 Rz 56.
- 81 REY, Rz 394.
- 82 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 88 mit dem Hinweis, dass der Richter hier eine Wertung vornehmen und diese klar offenlegen müsse; SCHWENZER, Rz 14.11.
- 83 BGer 4A_127/2011, E. 12.1.
- 84 BGE 126 III 388, E. 10.
- 85 BGE 117 II 394, E. 3.
- 86 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 7; REY, Rz 344.
- 87 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 7; OFTINGER I, S. 60; REY, Rz 342.
- 88 REY, Rz 340 f.
- 89 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 7; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 26; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 26; REY, Rz 334.
- 90 BGE 118 II 176, E. 4.c.
- 91 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 138; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 7; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 44; KELLER/GABI/GABI, S. 16; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 26; REY, Rz 343; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 59; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 9; SCHWENZER, Rz 14.27 f.
- 92 BGE 127 III 73, E. 3.a.
- 93 KELLER/GABI/GABI, S. 16; OFTINGER/STARK I, § 2 Rz 61.
- 94 BGE 118 II 176, E. 4.b; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 10; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 59.
- 95 BGE 127 III 403, E. 4.a; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 11; KELLER/GABI/GABI, S. 16.
- 96 GL.M. SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 56.
- 97 BGE 84 II 158, E. 2 betr. verbleibender Minderwert.

- 98 BGE 127 III 73, E. 5.b; 118 II 176, E. 4.b; 116 II 480, E. 4; BK-BREHM, Art. 41 OR N 77; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 12; KELLER/GABI/GABI, S. 17; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 25; REY, Rz 306.
- 99 BGE 118 II 176, E. 4.c.
- 100 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 12.
- 101 So u.a. BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 12 mit dem Hinweis, dass dies sowohl auf bloss molekularer Ebene als auch als Ganzes möglich sei, weshalb dies auch der Fall bei einer radioaktiven Verstrahlung sei (BGE 116 II 480, E. 5.b).
- 102 REY, Rz 306a unter Verweis auf BGHZ 55, S. 153 ff.
- 103 REY, Rz 306a; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 16, stimmen dem Urteil BGHZ 55, S. 153 ff. zu, in dem der BGH entschied, dass eine Eigentumsverletzung nicht notwendig eine Beeinträchtigung der Sachsubstanz voraussetze, sondern auch durch Einwirkung auf die Nutzungs- bzw. Verkaufsfähigkeit erfolgen könne. – Keine Substanzverletzung lag auch im Weinkorken-Fall vor, BGHZ 101, S. 337 ff.
- 104 BGE 118 II 176, E. 4.b; KELLER/GABI/GABI, S. 17; OFTINGER/STARK I, § 6 Rz 354; REY, Rz 306b; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 10.
- 105 Vgl. zum Meinungsstand REY, Rz 308a. Für BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 12, wird die Computersoftware physisch abgespeichert, wodurch die bspw. durch Viren beschädigte Software als Sachschaden einzustufen sei. Dies, d.h. eine Eigentumsverletzung, lehnen HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 18, ab, da eine EDV-Datei keine Sache sei, auch wenn sie auf einem Datenträger gespeichert werde. Hierfür stünde – bei Vorsatz – Art. 144^{bis} StGB (mögliche Datenbeschädigung) als Schutzgesetz zur Verfügung. Für Sachschaden ist wiederum BK-BREHM, Art. 41 OR N 78c.
- 106 BGE 118 II 342, E. 2 = Pra 82 (1993), Nr. 211; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 12.
- 107 BGE 133 III 323, E. 5.1; BK-BREHM, Art. 41 OR N 85; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 13; KELLER/GABI/GABI, S. 17; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 25; REY, Rz 329; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 10; SCHWENZER, Rz 14.16.
- 108 GL.M. und gleiche Einteilung KELLER/GABI/GABI, S. 17.
- 109 Die hier verwendete Terminologie weicht insofern von der herrschenden ab, als hier unter «sonstigem Schaden» nicht alle Schäden verstanden werden, die nicht aus Tötung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Zerstörung oder Verlust entstehen (vgl. aber N 53), sondern nur derart entstandene, die wegen einer Rechtsverletzung aber ersatzfähig sind. Der Vorteil ist, dass nicht einerseits erklärt werden muss «In der Regel sind solche Schäden [sc. sonstige Vermögensschäden; der Verfasser] nicht ersatzpflichtig» (so aber u.a. BK-BREHM, Art. 41 OR N 85), dann aber andererseits wieder ersatzfähige Ausnahmen definieren zu müssen (BK-BREHM, Art. 41 OR N 85a). Nach der hier vertretenen Einteilung bilden die übrigen, unter keinem Titel ersatzfähigen Schäden die sog. «reinen Vermögensschäden», die konsequenterweise nun nicht nur die Vermögensschäden Dritter (Reflexschäden) umfassen (so aber HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 20; sinngemäss wohl auch REY, Rz 332).
- 110 BGE 106 II 75, E. 2; zur allfälligen Konkurrenz zwischen der allgemeinen Haftungsordnung von Art. 41 ff. OR und den Spezialgesetzen vgl. vorne N 4 f.
- 111 BGE 112 II 118, E. 5.e; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 274; GAUCH, recht 1996, S. 234; KELLER/GABI/GABI, S. 43; OFTINGER I, S. 134 f.; OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 55 f.; OFTINGER/STARK II/2, § 24 Rz 30 ff.; REY, Rz 669; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 135.
- 112 So SCHWENZER, Rz 50.04; gl.M. KELLER/GABI/GABI, S. 43; OFTINGER/STARK II/1, § 16 Rz 41; REY, Rz 666 f.; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 134; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 21. – CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 42, weist zu Recht darauf hin, dass nicht ersichtlich ist, weshalb der Widerrechtlichkeit diese haftungsbegrenzende Funktion mehr zukommen solle als den anderen Haftungsvoraussetzungen, die ebenfalls haftungsbegrenzend wirkten.
- 113 GIGER, Berührungspunkte, S. 377; KELLER/GABI/GABI, S. 44; VON TUHR/PETER, S. 408. – MERZ, S. 306, erklärt bezüglich des Begriffs «Widerrechtlichkeit», dass «seine Selbstverständlichkeit und seine Inhaltslosigkeit» auffalle; auf S. 311 spricht er von «Generalklausel».
- 114 Vgl. u.a. GABRIEL, Rz 1 ff.; GAUCH/SWEET, S. 117 ff.; JAUN, S. 749 ff.; PORTMANN, SJZ 1997, S. 273 ff.; RASCHEIN, S. 1 ff.; ROBERTO/RICKENBACH, S. 185 ff.
- 115 BGE 133 III 323, E. 5.1; 123 II 577, E. 4.b; 123 III 306, E. 4.a; 122 III 176, E. 7.b; 119 II 127, E. 3; 115 II 15, E. 3.a; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 31.

- 116 SCHWENZER, Rz 50.04.
- 117 Zu den terminologischen Unterschieden zwischen der herrschenden Nomenklatur bei Vermögensschäden ohne Verletzung eines absoluten Rechtsgutes und der hier vertretenen Begrifflichkeit vgl. Fn 109.
- 118 **BGE 133 III 323**, E. 5.1 f. = **Pra 97 (2008), Nr. 7**; **132 III 122**, E. 4.1; **123 III 306**, E. 4; **123 II 577**, E. 4.c; BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 33 i.V.m. 35 ff.; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 31**; KELLER/GABI/GABI, S. 44; CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 43 i.V.m. 44 f.; REY, Rz 670 i.V.m. 672 f.; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 136 f.; **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 23**; SCHWENZER, Rz 50.04.
- 119 Eine der wenigen Ausnahmen, in der das BGer nicht auf diese Theorie abstellte, ist **BGE 82 II 25**. Hier erachtete es eine schwere Körperverletzung als nicht genügend für die Widerrechtlichkeit, sondern anerkannte die Widerrechtlichkeit nur unter Hinweis auf die Verletzung des Gefahrensatzes, d.h., es stellte neben der Verletzung eines absoluten Rechts noch zusätzlich auf ein Verhalten ab (gl.M. GAUCH, recht 1996, S. 232).
- 120 BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 35; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 33**; KELLER/GABI/GABI, S. 44 f.; OFTINGER I, S. 130; OFTINGER/STARK II/1, § 16 Rz 47; SCHWENZER, Rz 50.05; REY, Rz 686 ff., der den Besitz aber nicht zu den absoluten Rechten zählt, weil es sich beim Besitz «um das blosse Innehaben der tatsächlichen Sachherrschaft, an welche indessen bestimmte Rechtswirkungen geknüpft werden», handle (Rz 692); gl.M. CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 44.
- 121 **Befürwortend**: KELLER/GABI/GABI, S. 44 f. und 47; OFTINGER I, S. 130; ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, **Art. 41 OR** N 94; WIDMER/WESSNER, S. 102 (VE **Art. 46 OR**); **ablehnend**: **BGE 124 III 297**, E. 5.b und c; **121 III 350**; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 33** und 36 (abweichend zur Voraufgabe); CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 47; REY, Rz 717.
- 122 **BGE 119 II 127**, E. 3; **118 I 473**, E. 2.b; **118 Ib 163**; FELLMANN, ZSR 2009, S. 481; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 33**; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 2 Rz 5 und § 4 Rz 20 («Das Vermögen ist *kein absolutes Recht*»); OFTINGER/STARK II/1, § 4 Rz 30.
- 123 **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 33**; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 147.
- 124 **BGE 132 III 122**, E. 4; **126 III 521**, E. 2; **125 III 86**, E. 3; **119 II 127**, E. 3; **117 III 315**, E. 4.d; **117 II 270**; **116 Ia 359**, E. 4.b; **115 II 15**, E. 3.b und c; vgl. statt vieler REY, Rz 672 und 688; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 162.
- 125 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 162.
- 126 **BGE 117 II 259**, E. 3; **115 II 15**, E. 3 f.; OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 41.
- 127 **BGE 133 III 323**, E. 5 ff. = **Pra 97 (2008), Nr. 7**.
- 128 **BGE 116 Ia 162**, E. 2.c; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 34a**; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 26 ff.; OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 42 f.; OFTINGER/STARK II/1, § 16 Rz 103 ff.; REY, Rz 697.
- 129 **BGE 118 Ib 473**, E. 2.b; **116 Ib 193**, E. 2.a; **107 Ib 160**, E. 3.a; REY, Rz 711.
- 130 **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 35**.
- 131 **BGE 133 III 323** = **Pra 97 (2008), Nr. 7**; ROBERTO/RICKENBACH, S. 193, insb. Fn 40; VERDE, Rz 528 ff. mit Darstellung des Meinungsstandes in der Lehre.
- 132 VERDE, Rz 368.
- 133 VERDE, Rz 686.
- 134 **BGE 102 II 85**; **101 Ib 252**.
- 135 **BGE 133 III 323**, E. 5 ff. = **Pra 97 (2008), Nr. 7**; **129 IV 329**.
- 136 GABRIEL, Rz 284 und 886.
- 137 So schon SIMONIUS, S. 316 f.
- 138 GABRIEL, Rz 356.
- 139 FELLMANN, ZSR 2009, S. 476.
- 140 **BGE 115 II 15**, E. 3.a.
- 141 REY, Rz 681a.
- 142 FELLMANN, ZSR 2009, S. 476.

- 143 REY, Rz 679.
- 144 WIDMER/WESSNER, S. 96 f.
- 145 Ablehnend auch: BGE 115 II 15, E. 3.a; BK-BREHM, Art. 41 OR N 33e ff.; FELLMANN, ZSR 2009, S. 476 f.; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 32; KELLER/GABI/GABI, S. 44; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 43.
- 146 ROBERTO, Rz 04.48 ff.; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 26; SCHÖNENBERGER, S. 6 f.; SCHWENZER, Rz 50.04; CR CO I-WERRO, Art. 41 N 68.
- 147 FELLMANN, ZSR 2009, S. 477.
- 148 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 Rz 21; ROBERTO, Rz 04.48 ff.; SCHÖNENBERGER, S. 6 f.
- 149 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 26; SCHÖNENBERGER, S. 11 f.; SCHWENZER, Rz 50.04.
- 150 Vgl. die konzise Darstellung der Theorie bei SCHÖNENBERGER, S. 6 ff.
- 151 So BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 32c.
- 152 CR CO I-WERRO, Art. 41 N 71.
- 153 So die Zusammenfassung der Kritik durch BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 32c.
- 154 Vgl. statt vieler BGE 126 III 521, E. 2; 123 III 306; 122 III 176, E. 7.b; 119 II 127; anders noch BGE 82 II 25, wo die Verletzung eines absoluten Rechts nicht genügte (vgl. vorne Fn 119).
- 155 BK-BREHM, Art. 41 OR N 35 («Widerrechtlichkeit liegt einmal vor, wenn absolute Rechtsgüter verletzt worden sind»); OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 23 («Ihre Verletzung [sc. absolute Rechtsgüter] ist immer rechtswidrig»), Rz 24 («Das Erfolgsunrecht ist durch den eingetretenen schädigenden Erfolg charakterisiert; [...] Solange er [sc. der Erfolg] nicht eingetreten ist, liegt keine Rechtswidrigkeit im Sinne des Erfolgsunrechts vor»); CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 44 («[...] die Verletzung eines durch das Recht absolut geschützten Rechtsgutes [...] genügt, um Widerrechtlichkeit zu begründen»); ebenso KELLER A., Haftpflichtrecht I, S. 107. – Gemäss FELLMANN, ZSR 2009, S. 479, Fn 46, sowie FELLMANN/KOTTMANN, Rz 294, Fn 703, basiert auch MERZ, S. 309, auf diesem Widerrechtlichkeitsverständnis des Erfolgsunrechts. Gerade MERZ war es aber, der (mindestens indirekt) auch hier von einer Verhaltensnorm ausging (vgl. hinten N 84 ff.).
- 156 PORTMANN, SJZ 1997, S. 275 f.
- 157 PORTMANN, SJZ 1997, S. 275.
- 158 PORTMANN, SJZ 1997, S. 275.
- 159 Sonst muss auch die Tötung eines Menschen durch Blitzschlag als widerrechtlich qualifiziert werden, PORTMANN, SJZ 1997, S. 275.
- 160 PORTMANN, Rz 232.
- 161 PORTMANN, Rz 233.
- 162 PORTMANN, SJZ 1997, S. 277 f. – Vgl. auch die konzise Zusammenstellung der Thesen von PORTMANN bei FELLMANN/KOTTMANN, Rz 306 ff.; FELLMANN, ZSR 2009, S. 483 ff.
- 163 So bspw. OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 24: «Das Erfolgsunrecht ist durch den eingetretenen schädigenden Erfolg charakterisiert; er besteht immer in der Verletzung eines Rechtsgutes. Solange er nicht eingetreten ist, liegt keine Rechtswidrigkeit vor, wohl aber im Zeitpunkt der Rechtsgutverletzung.» Zu den weiteren Vertretern dieser Gleichsetzung vgl. vorne Fn 154 und 155.
- 164 So FELLMANN/KOTTMANN, Rz 313; FELLMANN, ZSR 2009, S. 485.
- 165 OFTINGER I, S. 132: «Rechtswidrigkeit fällt meist aber nicht notwendigerweise mit der Verletzung eines subjektiven, absoluten Rechts zusammen. Ist ein absolutes Recht verletzt, so ist die Widerrechtlichkeit von selber gegeben.»
- 166 MERZ, S. 301 ff. (insb. S. 309).
- 167 OFTINGER I, S. 132, Fn 30 (Hervorhebung durch Verfasser).
- 168 MERZ, S. 389.
- 169 MERZ, S. 309.
- 170 MERZ, S. 312.
- 171 KELLER/GABI/GABI, S. 47 (wie in der Erstauflage KELLER/GABI von 1985).

- 172 Aufzählung aus KELLER/GABI/GABI, S. 46 f.
- 173 KELLER/GABI/GABI, S. 47.
- 174 REY, Rz 686–691.
- 175 REY, Rz 672.
- 176 KELLER/GABI/GABI, S. 47.
- 177 OFTINGER I, S. 130 und 488, Fn 44; ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 41 OR N 94; VE Art. 46 OR: WIDMER/WESSNER, S. 102.
- 178 BGE 124 III 297, E. 5.b und c; 121 III 350; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 33 und 36; REY, Rz 717.
- 179 BGE 108 II 305, E. 2.b; BK-BREHM, Art. 41 OR N 53 m.w.V.; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 47; REY, Rz 717.
- 180 KELLER, recht 1987, S. 136.
- 181 Gemäss BK-BREHM, Art. 41 OR N 53a f.; KELLER/GABI/GABI, S. 48; REY, Rz 743 ff.
- 182 BGE 112 II 32, E. 2.
- 183 BGE 130 III 345; 121 III 350; 120 II 331 (in allen drei BGE wird die c.i.c. heute als Teil der Vertrauenshaftung qualifiziert).
- 184 BGE 111 II 471, E. 3 m.w.V.; 101 II 69, E. 2; 57 II 81, E. 2; REY, Rz 749.
- 185 BGE 101 II 69; REY, Rz 750 m.w.V.
- 186 KELLER/GABI/GABI, S. 49.
- 187 REY, Rz 717.
- 188 FEHLMANN, Rz 172.
- 189 BGE 57 II 81, E. 2.
- 190 BGE 111 II 471, E. 3.
- 191 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 344.
- 192 REY, Rz 722.
- 193 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 344.
- 194 BGE 116 II 695, E. 4; 112 II 347, E. 1.a; 111 II 471, E. 2; 57 II 81, E. 2 (betr. Dritthaftung).
- 195 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 344; REY, Rz 723 (jeweils mit weiteren Verweisen).
- 196 BK-BREHM, Art. 41 OR N 49a.
- 197 BGE 44 II 444; BK-MERZ, Art. 2 ZGB N 30.
- 198 BK-MERZ, Art. 2 ZGB N 29.
- 199 BK-MERZ, Art. 2 ZGB N 30.
- 200 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 29.
- 201 Vgl. die Rechtsprechungsanalyse aus dem Jahre 1984 bei FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 19 ff.
- 202 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 25.
- 203 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 26 m.V. auf KELLER, S. 102, der bereits 1948 in einem anderen Zusammenhang auf eine solche Pflicht ohne vorbestehende Sonderverbindung hinwies.
- 204 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 28 m.w.V.
- 205 GL.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 53, ohne Beschränkung auf die Berechtigung des Vertrauens.
- 206 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 30.
- 207 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 30.
- 208 FISCHER, ZVglRWiss 1984, S. 30.
- 209 GL.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 53i m.w.V.; KELLER/GABI/GABI, S. 47.

- 210 Gl.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 53i.
- 211 Dem Sinne nach auch BGE 124 III 297 durch Charakterisierung von Art. 2 ZGB als Schutzbestimmung.
- 212 BGE 134 III 390, E. 4.3.2; BERGER, Rz 1989 ff.; BK-BREHM, Art. 41 OR N 53e; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 44: eigenständige dritte Haftungsgrundlage zwischen Delikt und Vertrag; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 48.
- 213 So BK-BREHM, Art. 41 OR N 53 f. Gemäss BERGER, Rz 1989 ff., handelt es sich lediglich um zulässige Rechtsfortbildung im Rahmen einer Lückenfüllung.
- 214 Gl.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 53k m.V. auf Judikatur.
- 215 BGE 115 II 15, E. 3.b; BK-BREHM, Art. 41 OR N 35; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 37.
- 216 BGE 126 III 113, E. 2.a.
- 217 BGE 116 Ib 367, E. 4.c (Hervorhebung durch den Verfasser); 116 II 695, E. 4.
- 218 BGE 115 II 15, E. 4.a; 111 II 471, E. 3 f.
- 219 BGE 136 III 113, E. 3.2.
- 220 Vgl. statt vieler BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 37.
- 221 BGE 126 III 113, E. 2.a (Wer die Skipiste nahe an einem Skilift vorbeiführt, muss dessen Masten polstern); 123 III 306, E. 4 (Sperrung eines Sprungturms bei Niedrigwasser).
- 222 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 38; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 35 f.; OFTINGER I, S. 129; SCHWENZER, Rz 50.33.
- 223 Vgl. zum Ganzen BK-BREHM, Art. 41 N 44; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 38.
- 224 BGE 124 III 297; 123 III 306; 119 II 127, E. 3. – Auch die Rolle einer Schutznorm hat das BGer dem Gefahrensatz abgesprochen (BGE 124 III 297, E. 5.b f.; BGer 4C.119/2000, E. 2.b).
- 225 BK-BREHM, Art. 41 OR N 55; OFK-FISCHER, Art. 41 OR N 37; KELLER/GABI/GABI, S. 50 f.; OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 44; OFTINGER/STARK II/1, § 16 Rz 26 ff. und 107.
- 226 KELLER/GABI/GABI, S. 49 f.
- 227 KELLER/GABI/GABI, S. 51; gl.M. HUGUENIN, Rz 1983.
- 228 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 38; gl.M. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 4 Rz 35; REY, Rz 756 («In diesem Sinne kann der Gefahrensatz durchaus bei der Feststellung der Widerrechtlichkeit [ebenfalls] bedeutsam sein»).
- 229 BGE 133 III 449, E. 4.1; 130 III 345 (Liegenschaftenschätzer-Entscheid); 124 III 363, E. 5.b; 124 III 297, E. 5.c und 6 (Motor-Columbus-Entscheid mit Hinweis auf den Ausnahmecharakter der Vertrauenshaftung); 121 III 350 (Ringer-Entscheid); 120 II 331 (Swissair-Entscheid).
- 230 So BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 44 m.V. auf den grundlegenden Entscheid BGE 120 II 331 (Swissair-Entscheid).
- 231 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 44 m.V. auf BGE 124 III 363, E. 5; 116 II 695, E. 4; 111 II 471, E. 3.
- 232 BGE 121 III 350, E. 6 f. = Pra 85 (1996), Nr. 168.
- 233 BGE 120 II 331, E. 5.a.
- 234 BGE 128 III 324, E. 2.5.
- 235 So die Analyse von BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 44b. Sie selber treten gestützt auf die Lehre vom einheitlichen gesetzlichen Schuldverhältnis für eine quasi-vertragliche Haftung ein (N 44b a.E.).
- 236 BGer 4C.47/2004, E. 3.
- 237 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 44.
- 238 REY, Rz 37a.
- 239 SCHWENZER, Rz 52.03 m.V. auf BGer 4C.193/2000.
- 240 Gl.M. SCHWENZER, Rz 52.04.

- 241 So SCHWENZER, Rz 52.05 mit Aufzählung all der sich im Zusammenhang der Vertrauenshaftung stellenden Fragen.
- 242 Zur Kritik an diesem Haftungstyp vgl. auch BK-BREHM, [Art. 41 OR N 53 ff.](#)
- 243 BK-BREHM, [Art. 41 OR N 60](#); [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 39](#); KELLER/GABI/GABI, S. 54; OFTINGER I, S. 134; OFTINGER/STARK I, § 4 Rz 45; REY, Rz 757.
- 244 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 175.
- 245 Nach BK-BREHM, [Art. 41 OR N 60 ff.](#)
- 246 [BGE 125 IV 30](#); [124 IV 313](#), E. 3 und 4.
- 247 BGer [5A_561/2010](#), E. 3.2.
- 248 [BGE 123 II 577](#), E. 4.i.
- 249 [BGE 132 II 449](#), E. 3.2; BK-BREHM, [Art. 41 OR N 61](#); [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 52 N 23](#).
- 250 [BGE 134 III 193](#), E. 4.6 = [Pra 97 \(2008\), Nr. 103](#); BK-BREHM, [Art. 41 OR N 63](#).
- 251 BGer [4C.225/2003](#), E. 3 ff.; BK-BREHM, [Art. 41 OR N 63](#); [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 44 N 4](#) und [Art. 52 N 22a](#); OFTINGER/STARK II/1, § 16 Rz 239; REY, Rz 763.
- 252 VON TUHR/PETER, S. 419.
- 253 [BGE 136 III 401](#), E. 5.2.2 f.
- 254 [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 52 N 18](#).
- 255 VON TUHR/PETER, S. 419.
- 256 [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 52 N 18](#); VON TUHR/PETER, S. 419.
- 257 [BGE 113 Ib 420](#), E. 4.
- 258 [BGE 117 Ib 197](#), E. 5.c.
- 259 [BGE 133 III 121](#), E. 4.1.2; [127 IV 154](#), E. 3.a; [117 Ib 197](#), E. 3; [116 II 519](#), E. 3.b; REY, Rz 769.
- 260 [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 52 N 20](#).
- 261 [BGE 114 Ia 350](#), E. 6; [108 II 59](#), E. 3. – Zur weiterführenden Literatur vgl. REY, Rz 769.
- 262 [BGE 117 Ib 197](#), E. 3.b; [113 Ib 420](#), E. 6; REY, Rz 770 (Anwendung des sog. «therapeutischen Privilegs»).
- 263 [BGE 117 II 541](#), E. 3.
- 264 [BGE 104 II 184](#), E. 2. – Zur Problematik der Einwilligung in eine Sportverletzung vgl. [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 52 N 21](#); REY, Rz 771 ff. (insb. Rz 774 m.w.H.).
- 265 [BGE 101 II 177](#), E. 6.a.
- 266 KELLER/GABI/GABI, S. 20.
- 267 KELLER/GABI/GABI, S. 20.
- 268 [BGE 123 III 110](#), E. 2.a.
- 269 [BGE 133 III 462](#), E. 4.4.2 = [Pra 97 \(2008\), Nr. 27](#); [128 III 174](#) = [Pra 91 \(2002\), Nr. 124](#); BK-BREHM, [Art. 41 OR N 106 ff.](#); CHK-MÜLLER, [Art. 41 OR N 35](#).
- 270 [BGE 133 III 462](#), E. 4.4.2 = [Pra 97 \(2008\), Nr. 27](#); [125 IV 195](#), E. 2.b.
- 271 [BGE 133 III 153](#), E. 3.3; [132 III 715](#), E. 3.2; [113 Ib 420](#), E. 3; [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 15](#); CHK-MÜLLER, [Art. 41 OR N 36](#).
- 272 [BGE 126 III 14](#), E. 1.c (zu [Art. 56 Abs. 1 OR](#)); [122 III 229](#), E. 5.a (rechtmässiges Alternativverhalten).
- 273 [BGE 131 III 306](#), E. 3.2.1; [130 III 591](#), E. 5.3; [129 III 65](#), E. 3.2; BK-BREHM, [Art. 41 OR N 110](#); [BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 15](#); KELLER/GABI/GABI, S. 30; CHK-MÜLLER, [Art. 41 OR N 36](#); KUKO OR-SCHÖNENBERGER, [Art. 41 N 14](#).
- 274 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 85.
- 275 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 85 f. m.V. auf den illustrativen [BGE 132 III 715](#).

- 276 BGE 124 III 155, E. 3.d.
- 277 BGE 115 II 440, E. 5.a.
- 278 BGE 132 III 715, E. 2.2 ff.
- 279 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 19 m.w.V.
- 280 BGE 132 III 715, E. 2.3.
- 281 BGE 123 III 110, E. 3.a; 107 II 269, E. 3; BGer 5C.61/2004, E. 5.4; BK-BREHM, Art. 41 OR N 120; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 16; KELLER/GABI/GABI, S. 31; SCHWENZER, Rz 19.03.
- 282 BGer 6B_183/2010, E. 3; vgl. BGE 135 IV 56, E. 2.1; 129 II 312, E. 3 = Pra 93 (2004), Nr. 4; 129 V 177, E. 3.2; 123 III 110, E. 3.a.
- 283 BGer 4C.103/2005, E. 5.1.
- 284 CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 37.
- 285 BGE 131 IV 145, E. 5.1 = Pra 95 (2006), Nr. 70; 101 II 69, E. 3.a.
- 286 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 16.
- 287 BGE 135 IV 56, E. 2.2.
- 288 BGE 101 II 69, E. 3.b.
- 289 BGE 132 III 715, E. 2.2; 123 III 110, E. 2; BK-BREHM, Art. 41 OR N 122 m.w.N.
- 290 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 15; gl.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 122 mit Nachweis der zum Teil abweichenden Lehre und Praxis.
- 291 BGE 124 III 155, E. 3.d; 121 III 358.
- 292 BGE 115 II 440, E. 4.c.
- 293 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 18 m.w.V.
- 294 BGer 2C_834/2009, E. 2.3.
- 295 Vgl. Beispiele bei KELLER/GABI/GABI, S. 37 f.; für die Rechtsprechung: BGE 98 II 231, E. 6; 92 I 516, E. 8.c; 75 II 68, E. 2; 67 II 132; 41 II 90; 29 II 294.
- 296 BGer 4C.45/2007, E. 3.2; ebenso BGE 135 IV 56, E. 2.1; 129 II 312, E. 3.3 = Pra 93 (2004), Nr. 4; 116 II 519, E. 4.b; 95 II 630, E. 4; 92 I 516; 85 II 516; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 20; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 38. – A.M. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 Rz 37, sowie SCHWENZER, Rz 20.03, welche beide die Lehre von der Unterbrechung des Kausalzusammenhanges ablehnen.
- 297 BGE 90 IV 265, E. 2.b; ferner BGE 111 II 429; 100 II 134, E. 5.
- 298 Siehe dazu BGer 4A_385/2013, E. 4 ff.
- 299 BK-BREHM, Art. 41 OR N 141 f.
- 300 BGE 112 II 439, E. 1.d.
- 301 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 21b.
- 302 Vgl. die konzise Darstellung dieser Kausalitätsformen bei BK-BREHM, Art. 41 OR N 146 ff. (kumulative Kausalität); BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 24 (kumulative Kausalität) bzw. N 28 (Teil- oder Mitursachen).
- 303 BGE 112 II 87, E. 2.b; BGer 4A_259/2012, E. 3.1 ff.
- 304 Vgl. statt vieler REY, Rz 623 f. mit neuen Lösungsansätzen für das sich hier stellende Beweisproblem.
- 305 BGE 135 III 397, E. 2.2 f. = Pra 99 (2010), Nr. 7; vgl. auch BK-BREHM, Art. 41 OR N 147 ff.
- 306 BGE 116 Ia 162, E. 2.c; KELLER/GABI/GABI, S. 61; OFTINGER I, S. 141.
- 307 BK-BREHM, Art. 41 OR N 168.
- 308 KELLER/GABI/GABI, S. 61.
- 309 BK-BREHM, Art. 41 OR N 168; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 7; OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 13; REY, Rz 805.

- 310 BGE 111 II 429, E. 3.b; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 44 N 10; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 9 Rz 26; KELLER/GABI/GABI, S. 119; OFTINGER I, S. 139. – Teilweise a.M. oder ganz ablehnend: BGE 91 II 218, E. 2.c; BK-BREHM, Art. 44 OR N 35; OFTINGER/STARK II/1, § 20 Rz 156.
- 311 BK-BREHM, Art. 41 OR N 169; KELLER/GABI/GABI, S. 61; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 9; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 29.
- 312 BGE 90 II 9.
- 313 KELLER/GABI/GABI, S. 70; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 12.
- 314 BK-BREHM, Art. 41 OR N 181 ff. (m.V. auf andere Meinungen); KELLER/GABI/GABI, S. 72.
- 315 KELLER/GABI/GABI, S. 72; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 12.
- 316 BGE 104 II 184; 102 II 363, E. 4; 58 II 213; OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 123; OFTINGER/STARK II/1, § 18 Rz 37.
- 317 BK-BREHM, Art. 41 OR N 180.
- 318 BGE 117 II 231, E. 2.a.
- 319 BGE 123 III 306, E. 5.
- 320 BGE 117 II 231, E. 2.b; 112 II 26, E. 2.
- 321 BGE 117 II 231, E. 2.b; 90 II 9, E. 3.
- 322 BGE 126 IV 165, E. 4.
- 323 BGE 125 IV 242, E. 3.c; BK-BREHM, Art. 41 OR N 192 ff., unterscheidet zwischen: (a) böswilliger Absicht, die den rechtswidrigen Erfolg bezweckt (N 193), (b) dem einfachen (oder direkten) Vorsatz, bei der die schädigende Handlung nur Mittel zum Zweck ist (N 194) sowie (c) dem Eventualvorsatz (N 195).
- 324 KELLER/GABI/GABI, S. 62.
- 325 KELLER/GABI/GABI, S. 62; vgl. BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 45; REY, Rz 836.
- 326 BK-BREHM, Art. 41 OR N 196.
- 327 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 48a.
- 328 OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 51.
- 329 REY, Rz 844.
- 330 REY, Rz 844; ebenso BGE 116 Ia 162, E. 2; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 48a; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 Rz 18; KELLER/GABI/GABI, S. 63; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 11; OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 83; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 33; SCHWENZER, Rz 22.15.
- 331 BGE 101 IV 80, E. 3.
- 332 Freier Weidegang im Jura von 1384 bis 29.09.1959: BGE 85 II 243, E. 1.
- 333 GL.M. KELLER/GABI/GABI, S. 64; vgl. auch die Kasuistik zu den Verschuldensgraden bei BK-BREHM, Art. 41 OR N 202 ff.
- 334 KELLER/GABI/GABI, S. 64.
- 335 BGE 100 II 332, E. 3.a; BK-BREHM, Art. 41 OR N 198; KELLER/GABI/GABI, S. 65.
- 336 BGE 121 V 40, E. 3.b; 119 II 443, E. 2.a; 115 II 283, E. 2.a; 111 Ib 192, E. 3; 108 II 422, E. 2; 107 II 161, E. 7.c; BK-BREHM, Art. 41 OR N 197; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 49; KELLER/GABI/GABI, S. 64; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 15; OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 107.
- 337 KELLER/GABI/GABI, S. 64; vgl. zur Kasuistik BK-BREHM, Art. 41 OR N 201–204.
- 338 KELLER/GABI/GABI, S. 64; OFTINGER/STARK I, § 5 Rz 109.
- 339 KELLER/GABI/GABI, S. 64 f.
- 340 KELLER/GABI/GABI, S. 65.
- 341 BGE 100 II 332, E. 3.a; BK-BREHM, Art. 41 OR N 198; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 Rz 28.
- 342 REY, Rz 861.
- 343 Vgl. zum Ganzen BK-BREHM, Art. 41 OR N 222 ff.

- 344 BK-BREHM, Art. 41 OR N 238.
- 345 KELLER/GABI/GABI, S. 59.
- 346 BGE 100 II 200, E. 17.b (Auszahlung von Vermögen des «front de libération nationale FLN» an den Hinterleger statt an den requirierenden algerischen Staat); vgl. auch BGE 96 II 145, E. 5 (Bank rät der am Konto berechtigten Konkubine, das für sie bestimmte Vermögen vor der Witwe in Sicherheit zu bringen).
- 347 CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 55.
- 348 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 43 m.V. auf BGE 124 III 297, E. 5.e.
- 349 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 42; a.M. BK-BREHM, Art. 41 OR N 243; vgl. zum Vorsatz vorne N 163 f.